DOI: https://doi.org/10.30582/kdps.2023.36.4.297
UCI: G903:PD0-000036251

차용미술과 저작권법상 공정이용 판단 시 변형성 기준*

- Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith의 시사점을 중심으로

박 경 신**

논문

목 차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 소송 경과
1. 사실관계 및 하급심 법원의 판단
2. 대상판결의 내용

Ⅲ. 대상판결에 대한 검토 및 시사점
1. 대상판결에 대한 검토
2. 우리나라 저작권법 제35조의5상 시사점

Ⅳ. 결론

* 본고를 읽고 귀중한 조언과 논평을 해주신 익명의 심사위원들께 진심으로 감사드립니다.
** 이화여자대학교 법학전문대학원 겸임교수, 법학박사

※ 투고일자 : 2023년 11월 14일 / 심사일자 : 2023년 11월 30일 / 게재확정일자 : 2023년 12월 01일

초 록

타인의 저작물을 필연적으로 포함할 수밖에 없는 차용미술의 경우 원저작물이 갖는 목적과 다른 목적을 가지고 새로운 의미와 메시지를 전달한다고 하더라도 저작권법상 복제권 및 2차적저작물작성권과 충돌할 수밖에 없다. 특히 차용미술과 관련해서는 설사 차용이 저작권 침해에 해당하더라도 현행 저작권법의 체제 내에서 저작권 제한 사유에 해당하여 허용되는지 여부, 허용된다면 허용되는 범위가 주된 쟁점이 되는데 특히 저작권법 제35조의5의 저작물의 공정한 이용에 해당하는지 여부가 문제된다. 이러한 상황에서 미국의 팝스타 프린스(Prince)를 묘사한 앤디 워홀의 〈오렌지 프린스〉를 둘러싼 2023년 5월 18일 미국 연방대법원의 *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 판결은 국내외에서 큰 주목을 받고 있다.

이와 관련하여 본고는 대상판결을 검토하고 대상판결에서 제시된 공정이용 법리상 차용미술의 허용 범위와 관련한 우리 저작권법 제35조의5의 해석과 관련하여 적용할 수 있는 구체적인 판단 기준을 제언하고자 한다. 이를 위하여 제Ⅱ장에서 대상판결의 내용을 검토하고, 제Ⅲ장에서 대상판결의 의미를 변형성과 상업성을 중심으로 그간 차용미술과 관련된 미국 법원의 판결들과의 관계에서 검토하고 우리 저작권법 제35조의5의 해석상 시사점 및 활용 방안에 대해 살펴보고자 한다.

주 제 어

차용미술, 저작권법, 공정이용, 상업적 이용, 변형적 이용

Ⅰ. 서론

차용(appropriation)은 일반적으로 “대중문화, 광고와 매스미디어, 다른 예술가와 여타 다른 곳에서 일상적 이미지를 빌려와서 새로운 작품에 통합”[1] 시키는 창작 형태로 이해되는데 미술계에서 최근 시도되는 창작 방식은 아니며 의도와 방식의 변화만 있을 뿐 복제와 차용은 미술계의 오래된 전통이라고 할 수 있다.[2] 그러나 차용된 원저작물이 새로운 작품의 독창적 내용 속에서 통합을 이루고 새로운 맥락과 의미를 갖게 된다는 점에 동의하더라도,[3] 현행 저작권법상 저작권자의 허락 없이 저작물의 일부 또는 전부를 사용하는 행위는 필연적으로 저작권자의 배타적 권리와의 충돌을 야기하는데, 차용미술과 관련하여 국내외에서 꾸준히 제기되고 있는 저작권 분쟁들이 이를 잘 보여준다. 특히 차용미술과 관련해서는 설사 차용 행위가 저작권 침해에 해당하더라도 현행 저작권법의 체제 내에서 저작권 제한 사유에 해당하여 허용되는지 여부, 허용된다면 허용되는 범위가 주된 쟁점이 되는데 특히 저작권법 제35조의5의 저작물의 공정한 이용에 해당하는지 여부가 문제된다.

이러한 상황에서 미국의 팝스타 프린스(Prince)를 묘사한 앤디 워홀(Andy Warhol, 이하 “워홀”)의 〈오렌지 프린스〉를 둘러싼 2023년 5월 18일 미국 연방대법원의 판결(이하, “대상판결”)이 국내외에서 큰 주목을 받고 있는데 법조계와 미술계로부터 양측을 지지하는 59건의 법정조언자 의견서(amicus curiae brief)가 법원에 제출된 사실이 이를 잘 보여준다.

이와 관련하여 본고는 대상판결에서 제시된 차용미술의 허용 범위와 관련한 공정이용 법리를 검토하고 우리 저작권법 제35조의5의 해석과 관련하여 적용할 수 있는 구체적인 판단 기준을 제언하고자 한다. 이를 위하여 제Ⅱ장

1) William M. Landes, Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach, 9 GEO. MASON L. REV. 1, 1 (2000); Tate, APPROPRIATION in Glossary of Art Terms, 〈https://bit.ly/2Qx6AkH〉, (2023. 11. 30. 검색).
2) 이에 대한 자세한 논의는 박경신, “차용미술의 저작권법상 허용범위에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원, 박사학위 논문(2019), 10-36쪽.
3) 박일호, “미술작품의 표절에 관한 미학적 접근”, 『현대미술학회 논문집』, 제8호, 현대미술학회(2004), 98쪽.

에서 대상판결과 하급심 판결의 내용을 검토하고, 제III장에서 대상판결의 의미를 그간 차용미술과 관련된 미국 법원의 판결들과의 관계에서 검토하고 우리 저작권법상 시사점 및 활용 방안에 살펴보고자 한다.

II. 소송 경과

1. 사실관계 및 하급심 법원의 판단

(1) 사실관계

사진작가 린 골드스미스(Lynn Goldsmith, 이하 "골드스미스")는 1981년 12월 잡지 ≪뉴스위크(Newsweek)≫의 요청으로 프린스의 사진을 자신의 스튜디오에서 촬영하였으나 당시 해당 사진들은 잡지에 게재되지 않았다. 1984년 골드스미스는 1981년 촬영했던 사진들 중 한 장의 흑백 사진(이하 "이 사건 사진")을 워홀이 ≪배너티 페어(Vanity Fair)≫에 게재될 기사와 관련하여 작가 참고용으로 이용하는 조건으로 자신의 에이전시를 통하여 ≪배너티 페어≫에 이용허락을 하였다. ≪배너티 페어≫는 해당 사진을 바탕으로 워홀이 실크스크린 기법으로 제작한 〈퍼플 프린스(Purple Prince)〉를 1984년 11월호 기사에 함께 게재하였다. 한편 워홀은 이 사건 사진을 바탕으로 ≪배너티 페어≫의 의뢰를 받지 않은 15개의 작품들을 추가로 제작하여 회화, 드로잉, 스크린프린트 등의 다양한 방법으로 이용허락하거나 판매하였으며, 해당 작품들은 일명 '프린스 시리즈(Prince Series)'로 알려지게 되었다.

2016년 프린스가 사망하자, ≪배너티 페어≫의 모회사인 콩데 나스트(Condé Nast)는 프린스에 관한 특별호를 발행하기 위하여 앤디워홀재단(The Andy Warhol Foundation For The Visual Arts, Inc., 이하 "AWF")의 이용허락을 받아 '프린스 시리즈' 중 한 점인 〈오렌지 프린스(Orange Prince)〉를 특별호 표지에 게재하였다. 2016년 5월 특별호가 발간되자 골드스미스는 워홀이 이 사건 사진을 이용하여 다양한 작품을 제작하였다는 사실

을 인지하고, AWF에 저작권 침해 사실을 통지하였으나, AWF는 '프린스 시리즈'가 이 사건 사진의 저작권을 침해하지 않았다고 주장하면서 선제적으로 뉴욕남부연방지방법원에 골드스미스를 상대로 저작권 침해 부존재확인 소송을 제기하였고, 골드스미스는 저작권 침해 반소를 제기하였다.

그림 1. 골드스미스가 촬영한 이 사건 사진(1981년)(좌) 그리고
≪Vanity Fair≫(1984년 11월호)에 수록된 워홀의 〈퍼플 프린스〉(가운데)와
≪Vanity Fair≫(2016년 5월호) 표지로 실린 워홀의 〈오렌지 프린스〉(우)

(2) 1심 법원의 판단

공정이용 긍

우선 미국 저작권법 제107조 공정이용의 판단을 위하여 고려하는 첫 번째 요소인 이용의 목적과 성격과 관련하여 1심 법원은 '프린스 시리즈'는 프린스를 상처받기 쉽고 불편한 인물에서 과장된 상징적 인물로 변형하는 것으로 합리적으로 인식될 수 있다고 설시하면서 변형성을 인정하였다. 그 이유로 이 사건 사진이 프린스가 "편안한 사람(comfortable person)"이 아니라 "상처를 입기 쉬운 존재(vulnerable human being)"라는 것을 표현하였지만, 워홀의 '프린스 시리즈'는 이 사건 사진에서 프린스의 상체 부분을 제거하고, 얼굴과 목선의 일부만 남겼고, 골드스미스가 강조하고자 한 이 사건 사진에서 딱딱하게 나타난 프린스의 골격은 '프린스 시리즈' 중 일부 작품에서는 부드러워지고 다른 작품들에서는 윤곽 처리되거나 음영 처리되었으며, 이러한 변경은 원저작물과는 다른 미감과 특징을 야기하였다는 점을 들었다.[4] 이에 따라 법원은 영

리적 목적이 있다고 하더라도 변형적인 이용에 해당한다고 판단하여 공정이용의 첫 번째 요소는 공정이용에 유리하게 적용된다고 판시하였다.

두 번째 요소인 저작물의 성격에 있어서 1심 법원은 이 사건 사진이 미공개 저작물이라는 점은 일반적으로 공정이용의 판단에 유리하게 작용하지만, 골드스미스가 애초에 이 사건 사진을 작가 참고용으로 이용허락을 하였기 때문에 이 사건의 경우 공정이용의 판단에 있어서 미공개 저작물인지 여부는 영향이 거의 없다고 설시하였다.[5]

세 번째 요소인 저작물 전체와 관련하여 사용된 부분의 양과 실질성에 대해서 1심 법원은 이 사건 사진에 포함된 프린스의 머리의 포즈 및 각도가 '프린스 시리즈'에 복제되었으나, 이는 저작권 보호 대상이 아니며 워홀이 이 사건 사진에 나타난 방식대로 프린스의 머리와 목선을 사용하였지만 '프린스 시리즈'를 창작하면서 이 사건 사진에 포함된 저작권 보호 요소를 거의 모두 삭제하였다고 판시하였다.[6]

네 번째 요소인 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향에 대해서 1심 법원은 워홀의 독특한 미학을 나타내는 양식화된 작품들로 구성된 워홀의 '프린스 시리즈'가 친숙하고 사실적인 프린스의 사진의 대체물이라는 증거가 없으며, 골드스미스의 사진과 워홀의 작품들이 잡지나 음반 표지에 모두 사용된다는 사실만으로 잡지사나 음반 회사가 이 사건 사진을 대신해 워홀의 변형적인 작품에 대한 이용허락을 받을 것이라고 인정할 수 없다고 설시하면서 '프린스 시리즈'는 골드스미스의 작품들의 시장을 해치거나 해칠 가능성이 있는 대체물이 아니라고 판시하였다.[7]

(3) 항소심 법원의 판단[8]

우선 공정이용 첫 번째 요소에 관하여 항소심 법원은 골드스미스의 주관적

4) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 382 F.Supp.3d (S.D.N.Y. 2019), at 325-326.
5) *Id.*, at 327.
6) *Id.*, at 329-330.
7) *Id.*, at 330-331.
8) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021).

의도는 프린스를 "상처받기 쉬운 존재"로 묘사하고자 하는 것인 반면, 워홀의 주관적 의도는 프린스로부터 이러한 인간성을 제거하고 대신 인기가 많은 상징적 인물로 표현하고자 하는 것일 수 있다는 점을 인정하면서도, 원저작물의 변형적 이용에 해당하는지 여부는 단순히 진술되거나 인식된 작가의 의도, 평론가 또는 판사가 작품으로부터 끌어내는 의미나 인상 관람객이나 평론가의 인식 또는 작품에서 찾아볼 수 있는 의미나 인상에만 의존할 수 없으며, 변형성 여부는 원저작물을 "궁극적으로 상이하고 새로운" 예술적 목적과 성격으로 이용하는지, 이에 따라 새로운 저작물이 창작을 위해 이용한 "원재료"로부터 분리되는지 여부를 검토해야 한다고 설시하였다.[9] 이에 따라 항소심 법원은 이 사건 사진과 '프린스 시리즈'는 본질적으로 동일한 인물의 초상화라는 점에서 중요한 목적과 기능이 동일하며, 무엇보다도 '프린스 시리즈'는 이 사건 사진의 본질적 요소들에 상당한 변형을 가하거나 추가하지 않고 이러한 요소들을 유지하고 있고, 워홀이 변경을 가한 부분은 주로 일부 요소들을 확대하거나 최소화하기 위한 것으로 이러한 변경이 피사체에 대한 상이한 인상을 주기 위한 방식으로 이 사건 사진을 변경하긴 하였지만, 이 사건 사진은 '프린스 시리즈'의 창작의 토대인 점은 쉽게 인식 가능하다고 설시하면서 변형성을 인정하지 않았다.[10] 또한 법원은 '프린스 시리즈'가 상업적이지만 공익에 기여하는 예술적 가치를 창출한다는 점은 인정하면서도, 변형성이 인정되지 않은 상업적 저작물이 공익에 기여하거나 상업적 사용을 통한 수익을 비상업적 목적의 증진을 위해 사용된다고 하더라도 이 사건에서 공정이용의 인정에 중대한 영향을 미치지는 않는다고 판시하였다.[11]

두 번째 요소인 저작물의 성격에 대해서도 항소심 법원은 이 사건 사진이 창작적인 미공개 저작물로서, 골드스미스는 한정된 기간 동안 한 번의 이용허락을 했을 뿐이며 미공개 사진으로서의 성격도 여전히 변하지 않았다는 점은 공정이용 인정에 있어 불리하게 작용한다고 판시하였다.[12]

세 번째 요소인 저작물 전체와 관련하여 사용된 부분의 양과 실질성에 대해

9) *Id.*, at 114.
10) *Id.*, at 115.
11) *Id.*, at 42-45.
12) *Id.*, at 45.

대체물시장

서 항소심 법원은 '프린스 시리즈'는 양적으로나 질적으로나 이 사건 사진을 상당히 차용하였다는 결론을 내렸다.[13]

네 번째 요소인 저작물의 잠재적 시장이나 가치에 미치는 영향과 관련하여 항소심 법원은 '프린스 시리즈'의 1차 시장과 이 사건 사진의 시장이 중첩되지는 않지만, 이 사건 사진이 출판물에 편집 목적으로 이용허락이 이루어지거나 이 사건 사진 및 유사한 작품에 바탕을 둔 2차적저작물 창작을 위하여 이용허락이 이루어지는 시장에 '프린스 시리즈'가 인식 가능한 손해를 야기하기 때문에 공정이용의 인정에 불리하게 작용한다고 판시하였다.[14]

2차시장: 2차적저작물,편집저작물 작성을 위한 이용허락시장

2. 대상판결의 내용

항소심 법원의 판결에 대하여 AWF는 공정이용 판단의 첫 번째 요소를 제외한 나머지 요소들에 대한 판단에 대해서는 상고하지 않았고, 따라서 연방대법원에서는 공정이용 여부의 판단을 위한 첫 번째 고려 요소인 이용의 목적과 성격만이 쟁점이 되었다[15]

(1) 다수의견

1) 저작물의 이용 목적 및 성격 판단 요소

가. 변형성의 의의 및 정도

다수의견은 우선 공정이용의 첫 번째 요소의 판단에 있어서 핵심은 새로운 창작물이 단순히 원저작물을 대체하는 것인지 아니면 새로운 것을 추가하거나 다른 목적이나 성격을 가지는지 여부를 검토하는 것이라고 해석한 기존의 *Campbell* 판결[16]을 재확인하면서도, 대부분의 복제가 사후에 사회적으로 유용하다는 의미에서 별도의 목적을 가지고 있으며, 2차적저작물이 원저작물

13) *Id.*, at 119.
14) *Id.*, at 122.
15) 고서치(Gorsuch) 대법관 및 잭슨(Jackson) 대법관의 보충의견이 있으나 이하에서는 다수의견과 반대의견을 중심으로 검토한다.
16) *Campbell v. Acuff-Rose Music*, 510 U.S. 569 (1994).

에 새로운 것을 추가하였다는 사실만으로 공정이용으로 볼 수 없으며, 이용의 목적 및 성격을 판단함에 있어서는 별도의 목적이나 다른 성격이 있는지 여부와 그 정도가 고려되어야 한다고 판시하였다.[17] 특히 다수의견은 별도의 목적이나 다른 성격을 가진 이용은 "변형적(transformative)"이라고 할 수 있는데 "변형(transform)"이란 용어가 미국 저작권법상 공정이용 조항에는 포함되어 있지 않지만 다른 조항에서 찾아볼 수 있으므로 변형적인 정도가 중요하다고 설시하였다. 이에 따라 다수의견은 미국 저작권법은 저작권자가 "그 밖에 저작물이 개작, 변형, 또는 각색된 형태(any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted)"를 포함하여 2차적저작물을 작성할 배타적 권리를 갖는다고 규정하고 있으므로, 공정이용의 판단에 있어서 변형적 이용의 개념을 광범위하게 인정하는 경우 2차적저작물작성권이 제한되기 때문에, 원저작자의 2차적저작물작성권을 보호할 수 있도록 변형적 이용에 해당하기 위한 변형성의 정도는 반드시 2차적저작물로 인정되는 이상이어야 한다고 판시하였다.[18]

이울러 다수의견은 저작물의 이용이 별도의 목적이나 다른 성격을 가지고 있는지 여부는 이용의 상업적 성격과 균형을 이루어야 하기 때문에 원저작물과 새로운 이용이 동일하거나 유사한 목적을 가지고 있으며, 새로운 이용이 상업적 성격을 가진 경우 이용의 목적 및 성격 요소는 복제에 대한 다른 정당한 사유가 없는 한 공정이용의 인정에 불리하게 작용한다고 판시하였다.[19]

나. 저작물 이용의 범위

다수의견은 공정이용 조항, 특히 이용의 목적 및 성격을 판단하는 경우 저작권 "침해"라고 주장되는 특정 "이용"이 검토되어야 하며, 따라서 동일한 복제라도 다른 목적으로 이용된 경우에는 공정이용으로 볼 수도 있다는 점을 분명히 하였다. 이에 따라 다수의견은 이 사건은 골드스미스가 이 사건 사진을 ≪배너티 페어≫에 작가 참고용으로 이용허락을 한 이후 워홀이 ≪배너티 페어≫에 게재된 〈오렌지 프린스〉를 비롯한 총 16점의 '프린스 시리즈'를 제작

17) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 598 U. S. ____ (2023), at 15-16.
18) *Id.*, at 16.
19) *Id.*, at 19-20.

하고 2016년 AWF가 〈오렌지 프린스〉에 대한 상업적 이용허락을 한 부분에 대해서만 저작권 침해 주장이 제기되었기 때문에 다수의견의 분석 역시 이에 한정됨을 명확히 하였다.[20]

이에 따라 다수의견은 유명인의 초상사진의 전형적인 이용 방법은 잡지에 기사와 함께 수록되는 것으로 골드스미스 역시 프린스를 촬영한 사진들을 프린스에 관한 기사에 수록하기 위한 용도로 잡지사들에 이용허락을 하였으며, 2016년 프린스 사망 후에도 동일한 목적으로 이용허락을 하였고, 2016년 AWF 역시 〈오렌지 프린스〉를 잡지 표지에 수록할 수 있도록 이용허락을 하였다는 점에서 잡지 표지에 사용된 〈오렌지 프린스〉와 이 사건 사진의 목적이 실질적으로 동일하고, 모두 프린스에 관한 기사에 대한 도해로 잡지에 사용되었기 때문에 상황이 구별되거나 다르지 않으며 따라서 AWF가 〈오렌지 프린스〉를 이용허락한 행위는 이 사건 사진의 이용 목적과 동일하고 〈오렌지 프린스〉와 이 사건 사진이 서로 완벽한 대체물은 아니더라도 이용 목적을 공유한다고 판시하였다.

특히 다수의견은 이 사건 사진은 프린스를 편안하지 않고 상처받기 쉬운 사람으로 표현하고 있는 반면, 워홀의 작품은 그를 인기 있는 우상으로 표현하였기 때문에 새로운 가치 창출 또는 메시지를 전달하고 있으므로 변형적 이용이라고 볼 수 있으며, 잡지사가 이러한 차이를 인지한 상태에서 이 사건 사진이 아닌 워홀의 작품을 잡지 표지로 사용하였기에 워홀의 작품은 이 사건 사진을 대체하지 않는다고 해석한 반대의견에 동의하지 않았다. 그러면서 이용의 목적과 성격 요소에서 구매자가 원저작물 대신에 이를 사용한 새로운 저작물에 "미적으로 끌렸는지" 또는 구매자가 새로운 저작물이 전달하는 메시지를 선호하였는지 여부를 중요하게 고려하는 경우, 모든 새로운 저작물이 허용될 수 있게 되기 때문에 이러한 "잡지 편집자 기준(magazine editor test)"은 공정이용 판단에 있어서 적합하지 않다고 설시하였다.[21]

이에 따라 다수의견은 이 사건 사진과 AWF의 2016년 〈오렌지 프린스〉의 이용허락은 동일한 목적을 가지고 AWF의 이용이 상업적 성격을 가진다는 점은 복제에 대한 다른 정당한 사유가 없는 한 공정이용에 불리하게 작용하며

20) *Id.*, at 19-21.
21) *Id.*, at 23, n. 11.

변형성이 상업적 성격보다 우위에 있더라도 마찬가지라는 결론을 내렸다.[22)]

다만 다수의견은 이러한 결론이 원저작물의 상당한 분량을 이용한 2차적저작물이 공정이용으로 인정받을 수 없다는 점을 의미하는 것은 아니며, 워홀의 모든 작품과 모든 저작물 이용 양태에 공정이용 판단이 동일하게 적용될 수 없다는 점을 분명히 하였다.[23)] 이에 따라 다수의견은 워홀의 '수프 캔(Soup Cans)' 연작의 경우 원저작물인 수프의 로고는 수프를 광고하기 위한 목적으로 사용된 반면, 워홀의 '수프 캔' 연작은 소비문화에 대한 예술적 비평을 위한 것이므로 목적이 다르고, 광고용 로고를 대체하지 않으며, 워홀의 '수프 캔' 연작에서 수프의 로고는 워홀의 논평이 대상이 되기 때문에 워홀이 수프 제품의 로고를 사용한 행위는 정당화될 수 있으며, 이에 따라 공정이용에 해당한다고 설시하였다.[24)]

2) 변형적 이용에서의 "새로운 표현, 의미 또는 메시지"에 대한 검토

다수의견은 *Campbell* 판결이 변형적 이용을 "새로운 표현, 의미 또는 메시지로 원저작물을 변경하는 것"이라고 설명하고 있지만, 이를 저작권법 제107조 제1항이 새로운 표현, 의미 또는 메시지를 추가하는 모든 저작물의 이용에 유리하게 작용하는 것으로 해석할 수 없으며, 의미나 메시지가 단순히 원저작물 및 그 목적과 구별되는 다른 목적이 있는지 또는 원래의 목적을 대체하는지 여부가 고려되어야 한다고 설시하였다.[25)]

다수의견은 법원이 특정 저작물의 예술적 중요성을 평가하고자 해서는 안 되고, 이용자의 주관적 의도나 법원의 주관적 해석이 이용 목적을 결정하지 않으며, 새로운 이용의 의미는 새로운 이용의 목적이 원저작물에 대한 논평, 비평, 그 밖에 이용이 불가능한 정보 제공 등과 같이 원저작물의 목적과 구별되는지 여부를 판단하기 위해 필요한 범위 내에서 고려되어야 함을 명확히 하였다.[26)]

다수의견은 이 사건 사진이 사실적인 반면, 워홀의 〈오렌지 프린스〉는 프린

22) *Id.*, at 24.
23) *Id.*, at 24-25.
24) *Id.*, at 26-27.
25) *Id.*, at 29.
26) *Id.*, at 31-32.

스를 상징적인 인물로 묘사한 것을 합리적으로 인식할 수 있다는 지방법원의 판단에 동의하면서도 이러한 차이점은 저작권 침해가 문제가 된 특정 이용의 맥락에서 평가되어야 한다고 설시하였다. 그러면서, 이 사건에서 문제가 된 AWF의 이용은 〈오렌지 프린스〉가 잡지 표지에 사용되도록 상업적 이용허락을 한 것이며 〈오렌지 프린스〉의 이용 목적은 여전히 프린스에 대한 기사를 설명하기 위한 것이기 때문에, 〈오렌지 프린스〉가 골드스미스의 이 사건 사진과 다소 다르게 프린스를 묘사하였다 하더라도 이 정도의 차이는 이용의 구체적 맥락을 고려할 때, 공정이용 판단을 위한 첫 번째 요소가 AWF에게 유리하게 적용되기에 충분하지 않다고 설시하였다.[27]

한편 저작물 이용의 또 다른 목적이 유명인의 "비인간적인 성격(dehumanizing nature)"과 "효과(effects)"에 대한 논평이라는 AWF의 주장에 대하여, 다수의견은 워홀의 많은 작품들과 특히 그의 반복적인 이미지 사용은 의심할 여지없이 유명인들을 상품으로 묘사하는 것으로 인식될 수 있으며, 이러한 논평이 프린스의 사망 시 "Prince Rogers Nelson, 1958-2016"에 대한 헌사의 의미로 ≪콩데 나스트≫의 표지에서 인식될 수 있을지라도 이 사건 사진에 대한 비판적 논평이 없으므로 원저작물의 차용의 정당성은 약화되는 반면, 상업적 성격의 비중은 커진다고 판시하였다.[28] 이에 따라 다수의견은 AWF가 주장하는 논평은 원저작물을 논평의 대상으로 하지 않는 풍자와 마찬가지로 "독자적으로 성립할 수 있으며(can stand on its own two feet)", 따라서 타인의 저작물의 차용행위에 대한 정당한 근거가 요구되며, 특히 AWF가 이 사건 사진을 프린스에 관한 잡지에 설명을 위하여 상업적으로 이용한 것은 사진의 전형적인 이용 방법과 유사하기 때문에 그에 대한 특히 설득력이 있는 정당성이 필요함에도 불구하고, AWF는 원저작물과 다른 의미나 메시지를 전달하고 있다는 것 이외에 어떠한 개별적 정당한 근거도 입증하지 못했다고 판시하였다.[29]

27) *Id.*, at 33.
28) *Id.*, at 34.
29) *Id.*, at 35.

(2) 반대의견

케이건(Kagan) 대법관과 로버츠(Roberts) 대법원장은 반대의견에서 워홀은 프린스의 머리를 전체 틀에 채우기 위하여 이 사건 사진을 자름으로써 프린스의 머리가 마술처럼 공간에 매달려있는 것처럼 분리가 되었고, 워홀은 이를 명암대비를 더 높인 이미지로 변환하여 실크스크린에 포함시켰는데 이 이미지는 프린스의 머리의 가장 어두운 부분을 분리시켜 과장하는 한편 프린스의 자연스럽고 각진 자세를 축소시킴으로써 정면을 향하는 방식으로 프린스를 묘사하였다는 점에서 변형성을 인정하였다.[30] 나아가 반대의견은 시각적 결과물의 차이를 지적한 전문가들의 의견을 인용하면서 이 사건 사진과 〈오렌지 프린스〉는 구성, 설명 방식, 컬러 팔레트(color palette) 및 매체, 즉 거의 모든 미적 특징에 있어서 "실질적으로 차이가 있으며", 골드스미스는 프린스의 "독특한 인간성"에 중점을 두었고 이는 물질성(corporeality)과 광도(luminosity)에서 보여지는 반면, 워홀이 중점을 둔 대상은 "개인(private person)"이 아닌 "공적 이미지(public image)"이며, 워홀은 프린스의 분리된 머리를 납작하게 만들어 자르고 이국적인 색을 사용하여 부자연스럽게 묘사함으로써 유명인 문화와 개인적·사회적 영향에 대한 새로운 메시지를 전달한다고 설시하였다.[31] 또한 반대의견은 전문가들의 의견을 바탕으로 워홀의 캔버스에서 프린스는 실제 사람이 아닌 "유령 같고(spectral), 어두우며(dark), 기괴한(uncanny)" 마스크와 같은 복제품으로 표현되며 가상의 "아이콘이나 토템"으로 재구성되고, 상품화된 이미지를 포장해서 배포하는 홍보 장치의 산물이 되었기 때문에 이 사건 사진과 워홀의 〈오렌지 프린스〉는 근본적으로 상이하며, 잡지사의 편집자가 미감 및 의미에서의 이러한 차이를 인지하고 이 사건 사진이 아닌 워홀의 초상화를 사용하기를 원했기 때문에 워홀의 〈오렌지 프린스〉가 원저작물인 이 사건 사진을 대체하지 않는다고 판단하였다.[32]

이에 따라 이용의 상업성과 관련하여 반대의견은 워홀의 이용에 상업적 측

30) opinion of KAGAN, J, 598 U. S. ____ (2023), at 8.
31) *Id.*, at 9.
32) *Id.*, at 9.

면이 인정되지만, 새로운 작품이 변형적일수록 상업성과 같이 공정이용의 판단에 불리하게 작용하는 다른 요소들의 중요성은 줄어든다고 판단하였다.[33] 반대의견은 이용의 성격에서 성격은 일반적으로 현저히 두드러지고 구분하는 역할을 하는 "주된 또는 본질적인 성질"이며, 목적은 의도되거나 도달된 "목적, 효과 또는 결과"라고 정의하면서, 작가가 원저작물을 이용한 행위의 본질적이고 구별되는 성질은 일반적으로 예술적 기교를 포함하는데 다수의견의 분석에 있어서 이러한 이용의 "성격"을 도외시하고, 워홀이 $10,000를 받고 이용허락을 한 사실만이 강조되었다고 비판하는 한편,[34] 이용의 목적 역시 지나치게 좁게 해석하여 프린스 작품의 목적이 대가를 받고 프린스에 관한 잡지 기사에서 프린스를 묘사하는 것으로 한정하여 작가가 가장 본질적으로 전달하고자 한 바를 간과하였다고 비판하였다.[35]

이에 따라 반대의견은 공정이용의 첫 번째 고려요소 판단 시 워홀의 "새로운 작품이" 별도의 목적이나 다른 성격을 가지고 새로운 무엇인가를 추가했는지를 평가해야 하며, 워홀의 〈오렌지 프린스〉는 이러한 요건을 충족한다고 판시하였다.[36]

III. 대상판결에 대한 검토 및 시사점

1. 대상판결에 대한 검토

(1) "변형적 이용(transformative use)"의 범위 제한

전통적으로 차용행위가 미국 저작권법상 공정이용에 해당하는지에 대한 판단과 관련하여 미국 법원이 특히 주요하게 고려하는 요소는 "변형적 이용(transformative use)"이다. 이는 원저작물을 어느 정도, 어떻게 또는 왜 변

33) *Id.*, at 17.
34) *Id.*, at 19-20.
35) *Id.*, at 20.
36) *Id.*, at 35.

형시켰는지 여부라고 할 수 있는데, 1990년 연방지방법원의 피에르 레발(Pierre N. Leval) 판사의 논문에서 유래한 개념이다. 레발 판사는 이용의 목적 및 성격 요소의 판단은 변형적인지 여부에 중점을 두어야 하며, 원저작물을 변형함으로써 후속 작가가 창작적 요소를 추가하였기 때문에 복제가 정당화될 수 있다는 의견을 표명하였다.[37]

이후 *Campbell* 판결에서 연방대법원은 이용의 목적 및 성격과 관련하여 가장 핵심은 "새로운 작품이 단순히 원저작물을 대체하는 것인지 아니면 별도의 목적과 다른 성격이 수반되고 새로운 표현, 의미 또는 메시지를 통하여 원래의 창작물을 변경하여 새로운 무엇인가를 부가하는지 여부 및 만약 그렇다면 어느 정도로 그러한지"라고 설시하면서 저작물의 이용이 변형적일수록 공정이용에 해당할 가능성이 크다고 판시함으로써 변형성의 개념을 구체화하였다.[38] 이 판결 이후 지난 30여 년간 공정이용 판단 시 첫 번째 고려 요소에 대한 실무상 분석은 저작물의 새로운 이용이 변형적으로 인식되는지에 대한 검토에 집중되었는데,[39] 이러한 경향은 2013년 *Cariou* 판결[40]에서 정점을 이루었다. 이 판결은 변형적 이용의 "최고 수위선(high-water mark)"이라는 평가를 받는데,[41] 항소심 법원은 새로운 이용이 다른 성격을 가지고, 원저작물에 새로운 표현을 추가하며, 원저작물과 구별되는 새로운 미학을 채택하여 "창조적이고 소통적인 결과(creative and communicative results)"를 만들어 내는 경우 변형성이 인정된다고 판시하였다.[42] 반면, 대상판결은 변형적 이용에 대한 이러한 단순한 해석을 거절하면서, 원저작물에 새로운 의미를 추가하는 새로운 표현을 덧붙였다는 사실만으로는 공정이용으로 인정되기에 충분하지 않으며, 이용의 목적 및 성격을 판단함에 있어서는 별도의 목적이나 다른 성격이 있는지 여부 및 그 정도가 고려되어야 한다고 판시하였다. 특히 대상판결은 공정이용의 판단에 있어서 변형적 이용의 개념을 광범위하게 인

37) Pierre Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 HARV. L. REV. 1105, 1111 (1990).
38) *Campbell v. Acuff-Rose Music,* Inc., 510 U.S. 569, 579 (1994).
39) Clark D. Asay et al., Is Transformative Use Eating the World?, 61 B.C.L. REV. 905 (2020).
40) *Cariou v. Prince,* 714 F.3d 694 (2d Cir, 2013).
41) *TCA Television Corp. v. McCollum*, 839 F.3d 168, 181 (2d Cir. 2016).
42) 714 F.3d 694, 707-708.

정하는 경우 저작권자의 2차적저작물작성권이 제한되기 때문에 원저작자의 2차적저작물작성권을 보호할 수 있도록 변형적 이용에 해당하기 위한 변형성의 정도는 반드시 원저작물의 2차적저작물로 인정되는 이상이어야 한다고 판시함으로써 향후 공정이용의 인정 범위가 협소해질 수 있음을 시사한다. 다만, 대상판결에서 쟁점은 워홀의 차용작품 자체가 아니라 워홀의 작품 이미지의 상업적 이용허락이 공정이용에 해당하는지 여부였으며, 대상판결에서 워홀의 '프린스 시리즈' 작품의 창작, 전시 또는 판매에 대한 공정이용 여부에 대해서는 전혀 고려하지 않았다는 점에서 대상판결의 적용 범위는 제한적이다.[43]

한편, 대상판결은 '수프 캔' 연작은 캠벨사의 로고와 목적이 다르기 때문에 공정이용에 해당할 수 있지만, AWF가 수프 제품을 제작하여 판매하는 회사에 워홀의 작품 이미지를 이용허락해 준 경우를 가정해 보면 워홀의 '수프 캔' 연작이 새로운 의미나 메시지를 가지고 있다고 하더라고 캠벨사의 로고와 동일한 목적을 가짐을 시사하였다.[44] 이러한 해석에 따르면 AWF가 잡지 표지에 〈오렌지 프린스〉를 이용허락하기 전까지는 공정이용에 해당한다고 볼 수 있으며, 이러한 분석 방식은 새로운 저작물의 창작, 즉 최초의 복제는 공정이용에 해당하는 경우라도 이후 저작물의 이용 방식에 따라 원저작물의 저작권자가 새로운 저작물에 대하여 저작권 침해를 주장할 수 있음을 암시한다. 즉, 타인의 저작물을 이용한 차용미술이 창작 이후 어떠한 목적으로 이용되는지 여부가 공정이용의 판단에 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 저작권법상 공정이용은 관련 상황에 따라 사법적 균형이 요구되는 일반적 원칙이며,[45] 따라서 각 사안의 구체적인 사실관계에 따라 원저작물의 이용 양태별, 이용자별로 분석되어야 하므로 〈오렌지 프린스〉와 창작, 전시나 판매, 〈오렌지 프린스〉 이미지의 이용허락 역시 복제의 목적을 감안하여 이용 형태별로 판단해야 한다고 본 다수의견은 타당하다고 본다.

나아가 대상판결은 공정이용 여부의 판단은 상업성, 복제의 이유를 비롯하

43) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 598 U. S. ____ (2023), at 21.
44) *Id.*, at 27, n. 15.
45) *Id.*, at 14.

여 원저작물의 이용의 목적 및 성격의 객관적 지표들을 조사함으로써 원저작물과 새로운 저작물 간의 이익의 균형을 도모해야 함을 명확히 함으로써 이용의 목적 및 성격을 판단하기 위한 요소로서의 변형성이라는 개념의 확대에 따라 야기된 불명확하고 예측 불가능한 공정이용 법리를 조명하였다고 볼 수 있다. 대상판결의 기준에 의하면 *Cariou* 사건의 경우 푸른색과 기타를 추가한 사실만으로는 변형성을 인정받기 어려울 수 있다.

한편 대상판결은 공정이용 항변에서 원저작물에 대하여 논평을 하거나 원저작물의 역사적 문맥과 관련이 있거나, 또는 "원저작물을 비평적으로 재언급"할 필요는 없다고 해석한 *Cariou* 판결[46]을 재확인하면서도, 패러디가 아닌 논평의 경우 저작물의 차용행위의 정당성이 더 엄격하게 요구됨을 확인하였다. 이와 관련하여 다수의견은 워홀의 '수프 캔' 연작과 〈오렌지 프린스〉를 구분하면서 두 작품 모두 상업주의에 대한 논평을 하였다는 점은 인정하면서도, 대량 소비의 상징인 캠벨의 로고는 그 자체가 논평의 대상이 될 수 있으며 따라서 워홀이 캠벨(Campbell) 수프의 로고를 사용한 행위는 정당화될 수 있는 반면, 〈오렌지 프린스〉는 원저작물에 대한 특별한 논평을 하지 않았고 따라서 적어도 AWF는 골드스미스의 저작물을 차용하는 데 대하여 "내가 더 좋게 만들 수 있다(I can make it better)"라는 것 이상의 정당성을 입증해야 한다고 설시하였다.[47]

그러나 대상판결에서 워홀의 '수프 캔' 연작에 대하여 인정된 소비문화에 대한 예술적 비평과 〈오렌지 프린스〉에 대해서는 인정되지 않은 유명인 문화에 대한 논평의 차이를 구분하기란 쉽지 않다. 게다가 캠벨의 로고가 논평의 대상이 될 수 있는 이유는 대중에게 잘 알려져 있으며 복제가 예상되고 대량 소비를 위한 일상품의 상징이라는 특징 때문인데, 이는 대중에게 유명하지 않은 저작물의 경우 논평의 대상으로 인정받기 더 어렵다는 의미일 수도 있다. 이에 따라 향후 차용미술 관련 저작권 침해소송에서는 이에 대한 입증이 더 첨예하게 다투어질 것을 보여진다.

46) 714 F.3d 694, 706 (2d Cir. 2013).
47) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 598 U. S. ____ (2023), at 34, n.21.

(2) 상업적 목적에 대한 고려

이번 판결을 통해 연방대법원은 공정이용의 첫 번째 고려 요소인 이용의 목적 및 성격의 판단에 있어서 변형성 이외에도 상업성과 같은 다른 요소들이 함께 고려되어야 함을 명확히 하였다. *Campbell* 판결 이후 미국 법원들은 이용의 목적 및 성격과 관련하여 변형성이 인지되는 경우 상업성에 대해서는 간과하는 경향이 있었는데 대상판결을 통해 상업성 역시 중요한 고려 요소이며, 변형성은 공정이용 분석에 있어서 결정적인 요소가 아니라 고려해야 하는 여러 요소들 중 하나일 뿐이라는 점이 명확해졌다. 즉, 원저작물과 후속 저작물이 다른 목적과 성격을 가지는지가 고려되어야 하며, 그 차이의 정도가 이용의 상업성과 균형을 이루지 않으면 공정이용을 인정하기 어렵다.

대상판결에서는 골드스미스의 이 사건 사진과 워홀의 〈오렌지 프린스〉가 프린스에 관한 전기적 이야기에 대한 도해로 사용되는 이미지의 이용허락 시장에서 경쟁 관계라는 점이 공정이용의 인정에 불리하게 작용하였는데, 따라서 향후 원저작물을 차용한 새로운 저작물이 원저작물과 동일한 목적을 가지고 있어 원저작물을 대체하고 상업적 성격이 인정되는 경우 원저작물을 차용한 작가는 차용에 대한 보다 강력한 정당한 사유를 입증해야 할 것이다. 즉, 차용작품이 아트 상품이나 굿즈에 사용되는 경우 원저작물의 저작자가 이미 이러한 상업적 목적으로 이용허락을 하고 있는지 여부가 고려되어야 하며, 원저작물의 복제에 대한 정당화 사유가 추가적으로 요구된다.

(3) 공정이용 분석에서 작가의 '의도'의 배제

1심 법원이 공정이용을 인정함에 있어서는 '프린스 연작'이 "프린스를 편안하지 않고 상처받기 쉬운 인간에서 과장된 상징적인 인물로 변형시킨 것을 합리적으로 인식할 수 있다"고 판시하는 과정에서 골드스미스가 이 사건 사진은 "프린스를 편안하지 않고 상처받기 쉬운 인간"으로 표현한 것이라고 증언하였다는 사실과 워홀 전문가가 '프린스 연작'에 대하여 "프린스는 일종의 상징이나 토템"이라고 한 증언이 어느 정도 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 반면 항소심 법원은 변형성 여부의 판단 시 단순히 진술되거나 인식된 작가의 의도, 평

론가 또는 판사가 작품으로부터 도출하는 의미나 인상에만 의존할 수는 없다고 설시하였다. 이에 대하여 대상판결의 다수의견은 이용의 목적 및 성격 요소가 공정이용에 유리하게 작용하는지 여부는 이용자가 원저작물을 통해 무엇을 하였는지에 대한 객관적 조사가 되어야 한다고 판시하였는데[48] 이는 보충의견이 판사는 작가가 특정 작업을 진행하면서 염두에 둔 목적을 추단해서는 안 된다고 설시한 것과 맥락을 같이 한다.

이를 통해 연방대법원은 이용의 목적에 대한 분석에 있어서 새로운 의미에 대한 고려는 합리적으로 인식될 수 있는 것에 한정되어야 하기 때문에 작가가 주장하는 작품의 의미나 법원이 작품에서 끌어내는 인상에 의해 변형성을 판단해서는 안 되며 작가의 의도나 작품의 의미에 대한 판단은 예술 평론가들의 영역이라는 점을 명확히 하였다.[49] 이는 저작물로 보호받는 표현에 대한 침해가 "고차원적 목적 또는 상이한 예술적 목적이라는 침해자의 주장에만 근거하여 정당화될 수 있다면 공정이용 항변에 대한 어떠한 실질적인 경계도 존재하지 아니하게 된다"고 판시한 *Rogers* 판결[50]과 맥락을 같이 한다.

이에 따라 향후 공정이용 판단에 있어서 작가의 시장에서의 유명세나 인기가 있는 작가의 발언이 공정이용의 판단에 있어서 미치는 영향력이 줄어들 것으로 보인다.

2. 우리나라 저작권법 제35조의5상 시사점

(1) 저작권법 제35조의5의 판단 기준

우리나라 저작권법 제35조의5 역시 미국 저작권법 제107조와 유사하게 공정이용 판단 시 고려해야 하는 4가지 요소들을 규정하고 있다. 그러나 미국 저작권법상 공정이용과 달리 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니

48) *Id.*, at 32.

49) *The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith,* 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021): 아울러 항소법원은 공정이용의 판단에 있어서 중요한 것은 "합리적 관찰자(reasonable observer)"가 타인의 저작물을 이용한 작품을 어떻게 인식하는지 여부이지 해당 작품에 대하여 예술가가 무엇을 말하는지가 아니라고 판시하였다.

50) 960 F2d 301, 310 (2d Cir 1992).

하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우이어야 한다고 명시하고 있다. '저작물의 통상적인 이용 방법'과 관련하여 이용자가 저작권법 제37조에 따라 제35조의5 공정이용에 해당하기 위해서는 저작물을 이용하는 자가 그 출처를 명시하여야 한다는 것이 주요하게 고려된다.[51] 대표적으로 '패션노조' 포스터 사건에서 항소심 법원은 "저작권법 제35조의3(현행 제35조의5)에 따라 저작물을 이용할 때 그 출처를 명시하였는지 여부는 저작물의 공정이용 여부 판단 시 중요한 고려사항이 된다고 보아야 할 것인데 출처를 명시하지 않은 채 원저작물을 사용하였는바 이는 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하거나 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치는 이용이라고 볼 여지가 큰 점" 등을 종합적으로 고려하여 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다.[52] 한편, "저작자의 정당한 이익"에 대해서는 재산적 권리에 관한 이익을 의미한다고 보기도 한다.[53]

그러나 차용미술과 관련하여 변형성을 비롯한 소정의 기준들을 제시한 다수의 판례가 축적되어 있는 미국과 달리 우리 법원에서 차용미술에 관한 판단이 이루어진 경우는 많지 않다.[54]

(2) 이용의 목적 및 성격 판단 시 "변형성"의 고려

1) 변형성 요건의 적용 가능성에 대한 검토의 의의

저작권법 제35조의5는 한·미 FTA의 체결에 따른 이행의 과정에서 신설되어 미국 저작권법 제107조와 유사하다고 할 수 있으며, 모방과 재현을 통한 원작의 해체라는 방식으로 새로운 메시지를 전달하고자 하는 차용미술의 본

51) 서울중앙지방법원 2015. 5. 8. 선고 2015노582 판결; 청주지방법원 2015. 8. 28. 선고 2015노288 판결; 대구지방법원 2016. 2. 26. 선고 2015고단6154 판결; 서울남부지방법원 2017. 4. 13. 선고 2016노1019 판결; 서울고등법원 2021. 8. 19. 선고 2020나2045644 판결 등.

52) 서울남부지방법원 2016. 6. 3. 선고 2016고정615 판결; 서울남부지방법원 2017. 4. 13. 선고 2016노1019 판결.

53) 서울중앙지방법원 2019. 8. 14. 선고 2018고정2866 판결; 수원지방법원 2020. 11. 13. 선고 2018노5567 판결 등.

54) 공정이용 규정이 신설된 후 2023년 3월 15일까지 공정이용이 쟁점이 된 판결·결정들의 요약과 평가에 관해서는, 이일호, "우리 저작권법상 공정이용의 운영 현황과 과제 - 판례를 중심으로 -", 『계간 저작권』, 제36권 제1호, 한국저작권위원회(2023) 참고.

질적 특성을 감안할 때 미국 저작권법상 이용의 목적과 성격(purpose and character of the use) 판단 시 미국 법원의 전통적인 고려 요소인 변형성 여부에 대한 검토는 차용미술과 관련한 저작권법 제35조의5의 해석에 있어서도 중요하다.

하급심 법원이 의료기기에 의한 치료행위를 건강보험심사평가원에 비급여 대상으로 신청하면서 타인의 논문을 복제하여 첨부서류로 제출한 사안에서 "저작물 이용의 목적이 원저작물과는 다른 변형적 방법이나 변형적 목적으로 이용되어 원저작물을 단순히 대체하는 것이 아니라 새로운 가치를 부여하였다면 공정이용으로 인정하기 용이"하다고 설시한 바 있으나,[55] 우리 저작권법상 공정이용 판단 시 고려 요소인 "이용의 목적 및 성격"과 관련하여 변형성에 대해 우리 법원의 본격적인 법리해석이 이루어지고 있다고 보기는 어렵다.

이러한 측면에서 이번 연방대법원의 판결이 원저작물에 새로운 표현을 추가하며, 원저작물과 구별되는 새로운 미학을 채택한 경우 변형성을 인정했던 그간 미국 법원들의 경향에 제동을 걸면서 원저작물에 단순히 형태적 변화를 가한 사실만으로 공정이용으로 인정하기는 충분하지 않으며, 이용의 목적 및 성격을 판단함에 있어서는 별도의 목적이나 다른 성격이 있는지 여부뿐 아니라 그 정도가 고려되어야 한다고 판시한 점은 우리 저작권법상 공정이용 법리해석 기준 논의에 시사하는 바가 크다. 게다가 단순히 "피상적 모방"이 아닌 "다른 텍스트와의 관계에서의 변형 혹은 각색"으로 볼 수 있는 패러디,[56] 특히 사회 비판 목적의 매개적 패러디나 비평적 목적 없이 기존의 저작물들을 발췌·결합하여 독립된 작품을 창작하고자 하는 목적을 가진 혼성모방적 패러디인 패스티시가 차용미술 분야에서 상당한 비중을 차지하고 있다는 점을 감안할 때 공정이용 논의에 있어서 변형성 여부는 중요한 쟁점이 될 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.[57]

2) 표현형식의 변형과 목적의 변형

우선 변형성의 검토에 있어서는 원저작물을 변형된 형식으로 이용하는 표

55) 서울중앙지방법원 2017. 6. 15. 선고 2016가합534984 판결.
56) Linda Hutcheon(김상구/윤여복 역), 『패러디이론』, 문예출판사(1995), 64쪽.
57) 박경신, "차용미술의 저작권법상 허용범위의 미적 판단 기준 - 절차적 기준 정립을 중심으로 -", 『계간 저작권』, 제33권 제1호, 한국저작권위원회(2022), 124-135쪽.

현형식의 변형과 저작자가 원저작물의 창작 시 의도한 해석 또는 메시지와 다른 의도를 가지고 원저작물을 이용하는 목적의 변형으로 구분할 필요가 있다.[58]

표현형식의 변형의 판단에 있어서는 구성, 설명 방식, 크기, 컬러 팔레트와 매체 등 형태의 차이가 판단 요소가 될 수 있다.[59] 그림책에 '평화의 소녀상' 조형물을 복제, 배포 및 전송하여 문제가 된 사안에서 하급심 법원이 그림책 전반에서 조형물 전체를 지면 대부분을 차지할 정도로 상당한 크기의 그림으로 나타내어 이용하고 있고, 그림책에 조형물과 "차별화되는 독창적인 내용은 없어 보인다"고 설시하면서 공정이용을 인정하지 않았는데,[60] 이는 표현형식의 변형이 인정되지 않은 경우로 볼 수 있다.

대체성이 있으면공정이용이 아니

반면 목적의 변형성 여부의 판단에 있어서는 원저작물이 이용된 맥락, 즉 원저작물의 목적과 구별되는 다른 목적이 있는지 또는 원저작물의 목적을 대체하는지 여부 및 그 정도가 고려되어야 한다. 목적의 변형성 여부는 공정이용의 네 번째 고려 요소인 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향과 "양적 연관성(positive association)"[61]이 있더라도 목적의 변형성은 현재나 잠재적 시장의 대체 여부를 고려하는 것이 아니라 목적의 대체 여부를 고려하는 것이고, 저작물의 새로운 이용이 저작권자에게 경제적 손해를 야기하는지 여부에 대한 검토를 하지 않기 때문에[62] 이 두 요소는 구별된다. 기자 채용시험 문제지 일부를 사진으로 찍어 시험 종료 후 해당 시험과 관련 없는 인터넷 게시판에 비방적인 글과 함께 무단으로 게시한 사안에서 법원은 게시 내용이나 목적이 시험문제 자체를 제공하는 데 있지 않으며, "문제의 내용을 비판할 목적"이라고 설시하면서 공정이용을 인정하였는데,[63] 이는 목적의 변형이 인정되는 경우로 볼 수 있다. 이와 유사하게 종교적

58) Rebecca Tushnet, Content, Purpose, or Both?, 90 WASH. L. REv. 869, 871-878 (2015): 레베카 투쉬넷 교수는 전자를 "내용 변형성(content transformativeness)"으로 후자를 "목적 변형성(purpose transformativeness)"으로 표현하였다.

59) 박경신, "[미국] 법원, 상당한 미적 변형이 없는 경우 공정 이용이 인정될 수 없다", 『저작권 동향』, 제16호, 한국저작권위원회(2017).

60) 서울중앙지방법원 2022. 1. 14. 선고 2021가합512773 판결.

61) *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith,* 598 U. S. ____ (2023), at 24, n. 12.

62) *Id.*

63) 서울중앙지방법원 2020. 5. 29. 선고 2019노2573 판결; 1심 법원은 게시 내용이나 목적이

그림을 해당 종교를 비판적 문구를 상단에 배치하여 웹페이지에 게재해 문제가 된 사안에서 법원은 이러한 행위는 이 사건 저작물이 형상화하는 특정 종교의 교리 이념에 대한 비판을 위하여 종교적·교육적인 목적으로 이루어진 것으로서 영리성이 있다고 보기 어렵다고 설시하면서 공정이용을 인정하였는데,[64] 목적의 변형성이 인정된 경우로 볼 수 있다.

이러한 표현형식의 변형과 목적의 변형이 모두 인정된 경우가 미국 제2순회항소법원의 *Blanch* 판결인데 여기에서 항소심 법원은 원저작물에서 샌들을 신은 여성 모델의 다리 부분을 차용한 후 이를 일부 변형하여 다른 이미지들과 함께 목가적 배경에 겹쳐 놓았을 뿐 아니라, 원저작물은 광고를 목적으로 촬영된 사진인 반면, 차용작품은 소비주의에 대한 논평을 목적으로 만들어졌다는 이유로 공정이용을 인정하였다.[65] 반면, 병행 수입업자가 정식 판매업자의 제품사진을 판매 사이트에 사용하여 문제가 된 사안에서 법원이 원저작물이 물품을 판매하기 위한 홍보 목적으로 사용되었고, 피고인은 원저작물 그 자체를 그대로 복사하여 사용하였던 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 공정이용을 인정하지 않았는데,[66] 표현형식의 변형성과 목적의 변형성이 모두 인정되지 않은 경우로 볼 수 있다.

그러나 이러한 표현형식의 변형과 목적의 변형이 완벽하게 분리되는 개념은 아니다. 표현형식의 변형 정도가 클수록 목적의 변형성이 인정될 가능성은 커진다. 이는 *Cariou* 판결에서 항소심 법원이 표현형식에 상당한 변경이 이루어진 25점의 작품에 대해서는 목적의 변형성을 인정한 반면 물리적으로 변경된 정도가 낮은 5점의 작품에 대해서는 원저작물에 대한 미세한 변경은 "새로운 저작물이 기인한 원저작물에 새로운 미학을 불어넣었지만", 이러한 정도의 변경은 공정이용을 인정하기에 충분하지 않으며, 단순히 미술 시장에서 차용미술로 지칭된다는 이유만으로 변형성이 인정될 수는 없다고 설시한 바에서 확인할 수 있다.[67] 반면 표현형식의 변형 정도가 적은 경우, 목적의 변형

기자채용 시험문제 자체를 이용자들에게 제공하는 데 있지 않고, 영리적인 목적으로 게시한 것도 아니라고 설시하였다. 서울중앙지방법원 2019. 8. 14. 선고 2018고정2866 판결 참고.

64) 수원지방법원 2021. 6. 17. 선고 2019나2718 판결.

65) *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 253 (2d Cir. 2006).

66) 수원지방법원 2023. 3. 9. 선고 2019가단548541 판결.

67) *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 699 (2d Cir. 2013).

정도가 중요하게 고려된다. 대상판결에서 〈오렌지 프린스〉의 경우 표현형식의 변형이 일부 인정되었지만, 〈오렌지 프린스〉의 이용 목적은 여전히 프린스에 대한 기사를 설명하기 위한 것이기 때문에, 〈오렌지 프린스〉에서 골드스미스의 사진과 다소 다르게 프린스가 묘사되었다 하더라도, 이러한 정도의 차이는 이용의 구체적 맥락을 고려할 때, 공정이용 인정에 유리하게 작용하지 않았다. 만약 워홀의 〈오렌지 프린스〉가 팝아트에 관한 특집 기사와 함께 미술 전문 잡지에 수록되었다면 목적의 변형이 인정되어 공정이용 인정 여부 결과가 달라졌을 수 있다.[68]

그렇다면 대상판결에서 검토되지 않은 작품의 창작에 원저작물이 차용된 경우에는 어떠한가?

일레인 스터트번트(Elaine Sturtevant)는 워홀, 로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein) 등 유명 작가들의 기법과 결과물을 복제하는 작업들을 계속하였는데 스터트번트의 대표작인 〈Warhol Flowers〉는 스터트번트가 워홀에게서 직접 실크스크린 원본을 얻어 작업 과정을 그대로 반복해 제작한 작품으로 워홀이 자신의 실크스크린 기법에 대한 질문을 받았을 때 "일레인에게 물어봐라(Ask Elaine)"라고 대답했다는 일화가 있을 정도이다.[69]

68) opinion of GORSUCH, J., 598 U. S. ____ (2023), at 6: 이와 같은 맥락에서 대상판결의 보충의견은 워홀의 프린스 이미지가 20세가 미술에 관한 논평을 하는 영리 목적의 도서에 수록된 경우에는 공정이용에 해당할 수도 있다는 해석을 하였다.

69) Jonathon Keats, Why Is This Warhol Hanging At MoMA? Because Elaine Sturtevant Painted It (And Quite A Few Lichtensteins Too), Forbes, November 25, 2014, 〈https://www.forbes.com/sites/jonathonkeats/2014/11/25/why-is-this-warhol-hanging-at-moma-because-elaine-sturtevant-painted-it-and-quite-a-few-lichtensteins-too/?sh=796fcb381a20〉, (2023. 11. 7. 검색).

그림 2. 워홀의 〈Flowers〉(1964)(좌)와 스터트번트의 〈Warhol Flowers〉(1965)(우)

일견 스터트번트의 차용작품은 그가 차용한 원저작물로 인식될 수도 있지만, 스터트번트는 의도적으로 자신의 차용작품이 원저작물과 정확하게 일치하지 않도록 변화를 두었는데 이러한 표현형식의 차이는 스터트번트의 〈Lichtenstein, Frighten Girl〉에서 잘 나타난다. 스터트번트의 〈Lichtenstein, Frighten Girl〉은 '크로핑(cropping)된' 인물에 사용된 컬러 팔레트, 외곽선, 여성의 피부에 사용된 벤 데이 도트(Ben-Day Dot)[70] 등에서 리히텐슈타인의 〈Crying Girl〉과 매우 비슷할 뿐 아니라, 두 작품 모두 바람에 날린 구불구불한 금발 머리, 통통한 체리 레드 색 입술과 이와 색이 맞춰진 손톱과 반짝이는 큰 눈물을 떨어트리는 격한 감정의 여성을 소재로 하고 있다는 점에서 동일하다.

그림 3. 리히텐슈타인의 〈Crying Girl〉(1963)(좌)과
스터트번트의 〈Lichtenstein, Frighten Girl〉(1966)(우)

출처: Whitney Museum of American Art; Christie's.

70) 특정 영역에 동일한 크기와 분포의 점들을 채워 넣는 기법을 의미한다.

스터트번트의 작품 속 여성은 리히텐슈타인의 작품 속 여성과 달리 밝은 푸른 색 눈동자를 가졌고, 오른쪽 배경의 일부가 검정색이 아닌 붉은색이며, 머리카락과 코 주위의 세부 묘사가 리히텐슈타인의 작품과 다르지만, 이 정도의 차이로는 표현형식의 변형의 정도가 크다고 보기 어렵다. 따라서 변형성 여부의 판단에 있어서 목적의 변형성의 정도가 중요해진다. 스터트번트는 저작자성(authorship), 독창성(originality), 창작성(creativity), 진본성(authenticity)과 같은 미술사의 주요 개념들에 의문을 제기하기 위하여,[71] 워홀, 리히텐슈타인뿐 아니라 클라스 올든버그(Claes Oldenburg), 키스 해링(Keith Haring), 재스퍼 존스(Jasper Johns)와 같은 팝아트로 명성을 쌓은 대표적인 작가들의 작품들을 차용하였다. 스터트번트는 자신의 차용의 목적을 "예술의 하부구조(understructure)"를 조사하는 것으로 밝히면서, "오직 표면을 다루는" 팝아트와 자신의 작품을 구분 지었다.[72]

팝아트가 일상적 오브제나 대중에게 익숙한 대중매체 속의 상업적인 이미지를 그대로 차용하여 콜라주, 확대, 반복, 복제 방식을 통해 해당 이미지들을 기존의 맥락에서 떼어내 다른 맥락에 배치함으로써 순수미술과 대중문화 간의 거리를 좁히고, 대중매체와 소비문화의 속성을 드러내고자 하였던 반면,[73] 스터트번트가 원저작물을 차용한 목적은 진본성, 도상성(iconicity), 예술적 명성 구축, 팝아트와 같은 미술 화풍에 대한 대중적 인기와 쇠락, 궁극적으로는 창작 과정 자체에 대한 논평을 하기 위한 것이라고 볼 수 있다.[74] 특히 스터트번트는 자신이 차용한 원저작자의 성명과 원저작물의 제호를 자신의 작품 제호로 사용함으로써 논평의 대상이 되는 원저작물과 원저작자를 명확히 나타냈다.

71) CastYourArt, "ELAINE STURTEVANT - THE ART OF APPROPRIATING ART", 2015. 3. 11., 〈https://www.castyourart.com/elaine-sturtevant-the-art-of-appropriating-art.html?lang=en〉, (2023. 11. 7. 검색).
72) Jonathon Keats, 앞의 글.
73) 박경신, 앞의 논문(주 2), 20쪽.
74) Margalit Fox, Elaine Sturtevant, Who Borrowed Others' Work Artfully, Is Dead at 89, The New York Times, May 16, 2014, 〈https://www.nytimes.com/2014/05/17/arts/design/elaine-sturtevant-appropriation-artist-is-dead-at-89.html〉, (2023. 11. 8. 검색).

3) 변형성 기준을 통한 공정이용과 2차적저작물의 관계 규명

이처럼 변형성의 판단에 있어서 표현형식의 변형과 목적의 변형으로 구분하는 경우 공정이용과 2차적저작물작성권과의 상호관계의 규명 역시 수월해진다.[75] 저작권법 제5조 제1항은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물은 2차적저작물로 보호된다고 규정함으로써 "변형"을 2차적저작물작성 행위 중 하나로 규정하고 있기 때문에, 차용미술이 공정이용에 해당하는지와 관련해서 발생할 수 있는 문제 중 하나가 2차적저작물작성권과의 관계이다. 이처럼 2차적저작물과 공정이용의 고려 요소인 변형은 모두 원저작물을 다른 매체 또는 표현 수단으로 이용하기 위한 변형이라는 점에서 공통점이 있기 때문에,[76] 공정이용 판단 기준으로서의 변형성과 2차적저작물의 성립 요건인 변형 상호 간의 관계 설정이 문제가 된다. 원저작물과의 사이에 실질적 유사성을 유지하면서 원저작물을 변형하여 2차적저작물로 인정되었음에도 공정이용의 변형적 이용에 해당하여 원저작자가 당해 2차적저작물에 대하여 아무런 권리도 행사하지 못하게 된다면, 사실상 원저작자의 2차적저작물작성권이 형해화된다.[77] 실제 *Cariou* 판결의 경우에도 공정이용을 이유로 원저작물의 2차적저작물 시장이 원천 봉쇄당했다는 비판이 제기되었다.[78] 따라서 공정이용의 변형성 이론의 해석에 있어 표현형식의 변형과 목적의 변형을 분리하여 판단하는 경우, 변형적 이용에 해당하지 않는 2차적저작물과 변형적 이용에 해당하는 공정이용을 용이하게 구별할 수 있다는 실익이 있다.[79]

이에 따라 목적의 변형 없이 실질적 개변을 통한 표현형식의 변형만이 이루어진 경우에는 2차적저작물에 해당할 뿐 공정이용상 변형적 이용으로 보기 힘들다.[80] 반면, 표현형식의 변형이 존재하는지를 2차적저작물 성립의 판단 기

75) 이에 대한 자세한 논의는 박경신, 앞의 논문(주 57), 127-128쪽.
76) 박준우, "2차적 저작물로의 변형과 공정이용인 변형의 차이 - 표현형식의 변형과 이용목적의 변형 -", 『상사판례연구』, 제22권 제4호, 한국상사판례학회(2009), 555쪽.
77) 박경신, 앞의 논문(주 57), 127쪽.
78) Liz Brown, Remixing Transformative Use: A Three-Part Proposal for Reform, 4 N.Y.U. J. INTELL. PROP. & ENT. L. 139, 160 (2014).
79) 박경신, 앞의 논문(주 57), 127-128쪽.
80) Shyamkrishna Balganesh & Peter S. Menell, Misreading Campbell: Lessons from Warhol, 72 Duke Law Journal Online 113, 141 (2023): 이와 같은 맥락에서 표현형식의

준인 실질적 유사성과 실질적 개변을 통해서 검토하고 표현형식의 변형이 존재하여 2처작저작물로 인정된다면 이후 목적의 변형이 있는지 여부를 검토하면 될 것이다.[81] 이는 변형적 이용의 개념을 광범위하게 인정하는 경우 저작권자의 2차적저작물작성권이 제한되기 때문에, 공정이용에 유리하게 작용하기 위한 변형성의 정도는 반드시 원저작물의 2차적저작물로 인정되는 이상이어야 한다고 설시한 대상판결과 맥락을 같이 한다.

마르샬 레스(Martial Raysse)는 전통적인 명화들을 모방한 일련의 작품을 아시아에서 생산된 값싼 모조품에 빗댄 '메이드 인 재팬' 시리즈를 선보였다. 그중 프랑스 신고전주의를 이끈 장 오귀스트 도미니크 앵그르(Jean Auguste Dominique Ingres)의 〈그랑드 오달리스크(La Grande Odalisque)〉의 얼굴 부분을 1964년 당시 처음 출시된 복사기를 이용해 확대 복사한 뒤 화려한 문양과 색채를 추가하고 작품 상단에 파리 한 마리를 추가한 〈메이드 인 재팬, 그랑드 오달리스크(Made in Japan, La Grande Odalisque)〉가 그의 대표작이다.

그림 4. 앵그르의 〈그랑드 오달리스크〉(1814)의 일부(좌)와
레스의 〈메이드 인 재팬, 그랑드 오달리스크〉(1964)(우)

출처: Louvre Museum; Centre Pompidou.

변형과 목적의 변형은 분리가 불가능하거나 목적의 변형 정도가 사소한 경우 2차적저작물작성권이 우선적으로 보호되어야 한다는 견해가 있다.

81) 박경신, 앞의 논문(주 2), 167쪽.

레스의 작품은 원저작물과의 실질적 유사성을 유지하면서도 화려한 문양과 현란한 색채를 추가함으로써 실질적 개변이 이루어졌다고 할 수 있으므로 표현형식의 변형이 인정되어 일단 2차적저작물에 해당하고, 나아가 형식적 측면을 중시한 신고전주의의 고전적인 미와 예술적 관습에 대한 도전 및 냉정한 비판과 풍자라는 목적의 변형 역시 인정되어(앵그르의 〈그랑드 오달리스크〉가 저작권 보호 대상이라는 가정하에) 공정이용에 해당할 수 있다.[82]

그렇다면 셰리 레빈(Sherrie Levine)의 〈워커 에번스 이후(After Walker Evans)〉와 같이 원저작물을 리포토그래피(rephotography) 방식으로 복제한 차용미술은 어떠한가? 레빈은 사진의 원본성과 독창성에 의문을 던지고 백인 남성 사진작가들의 관점과 예술계의 권력 구조를 비판하기 위하여[83] 사진 매체를 통해 유명 남성 작가들의 작품을 복제한 시리즈를 발표하였는데 'After'라는 단위 뒤에 자신이 차용한 남성 작가의 성명을 붙인 제목으로 발표한 'After' 시리즈가 대표적이다. 워커 에번스(Walker Evans)의 〈Alabama Tenant Farmer Wife〉를 차용한 〈After Walker Evans〉는 일견 에번스의 작품과 전혀 차이가 없는 것처럼 보인다.

그림 5. 에번스의 〈Alabama Tenant Farmer Wife〉(1936)(좌)와 레빈의 〈After Walker Evans〉(1981)(우)

출처: Metropolitan Museum of Art.

82) 박경신, 앞의 논문(주 2), 168쪽.

83) Corrina Peipon, Take It Or Leave It: Institution, Image, Ideology, Hammer Museum, 2014, 〈https://hammer.ucla.edu/take-it-or-leave-it/artists/sherrie-levine〉, (2023. 10. 8. 검색).

변형성이 인정되기 위해 반드시 표현형식의 변형이 요구된다면 도록에 수록된 에번스의 사진을 사진으로 재촬영한 〈After Walker Evans〉와 같이 원저작물의 표현형식을 그대로 복제하거나 표현형식에 일부 변경이 이루어졌지만 실질적 개변에 이르지 못한 차용미술은 목적의 변형 여부에 관계없이 공정이용의 범위에서 제외되어 복제권 침해가 인정되는 결과가 야기된다.[84] 그러나 검색을 위해 이용되는 썸네일 이미지와 같이 원저작물을 원래 크기보다 훨씬 크게 만든 차용미술의 경우 표현형식 그 자체는 변형성을 인정받지 못하더라도 원저작물의 이용 목적은 변형적일 수 있으며, 공정이용에 해당할 수 있다. 마찬가지로 소비자주의에 대한 논평을 하기 위하여 저작권 보호 대상인 광고 로고를 미술 작품에 완벽하게 복제한 경우라도 공정이용에 해당할 수 있다.[85]

당시 미국 농업안전국(Farm Security Administration)의 의뢰를 받아 촬영된 에번스의 작품들은 사실적이고 꾸밈이 없지만, 자신이 사진을 통해 기록하는 삶, 문화 및 공동체에 대한 복잡하고 상세한 세부 사항을 포착하고 있는데, 부유한 집안 출신이었던 에번스가 농장 노동자들을 촬영한 사진들은 외부인의 시각을 담고 있다.[86] 에번스의 목적은 사진을 "문학적이고 권위 있으며, 초월적으로" 만드는 것이었다.[87] 반면, 레빈은 이러한 대표적인 다큐멘터리 남성 사진작가의 작품을 복제하고 재현함으로써 사진의 원본성과 독창성에 의문을 던지는 한편 여성과 아동이 포함된 촬영 대상에 대한 남성 사진작가의 시선을 해체하고 부유한 집안 출신의 남성 사진작가로서 특권을 가졌던 에번스에 대하여도 보여준다.[88] 이러한 측면에서 레빈의 차용행위에 대해서는 목적의 변형이 인정될 수 있다.[89] 다만, 리포토그래피 방식의 차용미술과 같이

84) 박경신, 앞의 논문(주 2), 165쪽; 대상판결 역시 동일하게 복제해도 공정이용에 해당할 수 있다고 판시하였다. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith 598 U. S. ____ (2023), at 20.

85) *Id.*, at 24-25.

86) Walker Evans, Summary of Walker Evans, The Art Story, 〈https://www.theartstory.org/artist/evans-walker/〉, (2023. 10. 8. 검색).

87) Famous Photographers, Walker Evans, 〈https://www.famousphotographers.net/walker-evans〉, (2023. 10. 8. 검색).

88) Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith 598 U. S. ____ (2023), at 35.

89) Brian L. Frye, *After Andy Warhol?*, 63 IDEA 280, 282 (2023): 에번스의 작품 저작재산권

표현형식의 변형성이 전혀 인정되지 않는 경우에는 목적의 변형성 여부가 엄격히 검토되어야 하며, 표현형식의 변형 정도가 적은 경우, 목적의 변형 정도가 더욱 중요하게 고려된다. 또한 영리성을 비롯한 공정이용 판단을 위한 다른 고려 요소들을 종합적으로 고려하여 공정이용 여부를 최종적으로 판단해야 할 것이다.

이러한 측면에서 '패션노조' 포스터 사건에서 항소심 법원은 패러디가 성립하기 위해서는 "원저작물과 독립된 창작성"을 가지고 있어야 하고 "누가 보더라도 기존의 원작품을 과장하여 흉내낸 것으로 풍자하거나 희화화한 것이 명백하여야 한다"고 설시하였다.[90] 그러면서, 원저작물의 "상하좌우 여백을 약간 삭제"하였거나 문제가 된 포스터는 원저작물의 사진 부분을 제외한 전시안내 문구 부분을 삭제한 후 "그대로 삽입한 것에 불과"하고 어떠한 새로운 창작성이 더해지지 않았다는 이유로 패러디로 인정하지 않으면서도, 저작권법 제35조의5에 해당하는지 여부의 판단에 있어서 원저작물의 목적과 구별되는 다른 목적이 있는지 또는 원저작물의 목적을 대체하는지 여부 및 그 정도를 구체적으로 검토하지 않고, 원저작물의 소재가 된 특정인을 "조롱하고 비하"하기 위하여 원저작물을 이용한 행위가 저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에 해당하지 않는다고 판시한 점은 아쉽다.[91] 특히 저작권법 제35조의5와 같은 일반 조항을 통한 저작권 침해에 대한 정당화 사유를 판단할 때에는 구체적이고 상세한 설명이 이루어져야 한다는 점에서 더욱 그러하다.[92] 향후 원저작물에 대한 논평을 포함하지 않는 매개적 패러디나 원저작물이나 사회에 대한 풍자

만료 후 레빈이 에번스의 작품을 차용한 작품들에 대하여 저작자임을 선언하자, 에번스 재단은 해당 작품들을 일괄 구매하였다. 다만, 에번스의 작품은 미국 농업안전국의 의뢰를 받아 창작되었기 때문에 미국 저작권법상 정부저작물에 해당하며 애초부터 저작권 보호 대상이 아니라는 견해가 있다.

90) 서울지방법원 2001. 11. 1. 선고 2001카합1837 결정 참고: 패러디의 저작권법상 허용 여부와 관련하여 우리 하급심 판례는 기존에도 저작물의 패러디를 인정할 필요성을 인식하면서도 원작에 대한 비평 목적이 있는 경우에 한하여 저작권법 제28조 인용 조항하에서 허용되는 패러디로 인정하며 해당 저작물이 아닌 사회 전체에 대한 비평에 대하여서는 패러디로서 허용된다고 보기 어렵다는 입장을 보였다.

91) 서울남부지방법원 2016. 6. 3. 선고 2016고정615 판결; 서울남부지방법원 2017. 4. 13. 선고 2016노1019 판결.

92) 계승균, "패러디와 저작권 침해", 『저작권 문화』, 제314호, 한국저작권위원회(2020), 26쪽.

나 비평을 하지 않고 기존의 저작물들을 발췌·결합하여 독립된 작품을 창작한 혼성모방적 패러디(패스티시)가 저작권법 제35조의5에 해당하는지 여부에 대한 판단이 보다 적극적으로 모색될 필요가 있으며, 차용에 대한 표현형식의 변형성 및 목적의 변형성이 고려되어야 할 필요가 있다.

(3) 이용의 목적 및 성격 판단 시 상업성의 고려

궁극적으로 갤러리나 미술관에서의 전시, 작품 자체의 판매를 목적으로 하는 차용미술은 원저작물의 이용과 관련하여 상업적·영리적 성격이 완전히 부정될 수는 없기 때문에 저작물 이용의 목적 및 성격과 관련해서는 상업성·영리성 여부를 고려해야 하는지가 문제가 된다.

우리 저작권법상 공정이용에 해당하기 위해서 반드시 비영리적인 이용이어야만 하는 것은 아니지만 영리적인 목적을 위한 이용은 비영리적인 목적을 위한 경우에 비하여 허용되는 범위가 상당히 좁아진다.[93]

또한 이용 목적의 판단 시 공익성이나 공공성이 고려되기도 한다.[94] 대표적으로 그림책에 '평화의 소녀상' 조형물을 복제, 배포 및 전송하여 문제된 사안에서 법원은 "공정이용에 해당하는 범위는 그 이용이 공익적·공공적 목적과 성격을 갖는 경우에는 일반적인 미술저작물을 이용하는 경우보다 더 넓게 인정되어야 하고, 반면 상업적·영리적 이용에서는 더 제한적으로 인정되어야 한다"고 하여 공정이용 판단에서 공익 목적을 적극적으로 고려한 바 있다.[95]

2011년 공정이용 규정이 우리 저작권법에 신설될 당시 "보도·비평·교육·연구 등"을 공정이용 목적 예시로, "영리성 또는 비영리성 등"을 제1요소 고려사항 예시로 열거하였으나, "저작물 이용 활성화라는 공정이용 규정의 목적 달성"[96]을 위하여 2016년 저작권법 개정을 통하여 이러한 예시 문구들이 모두 삭제되었다.[97] "영리성 또는 비영리성 등"의 수식어를 저작물 이용의 목적

93) 서울중앙지방법원 2022. 1. 14. 선고 2021가합512773 판결.
94) 서울고등법원 2005. 7. 26. 선고 2004나76598 판결; 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005도7793 판결; 서울중앙지방법원 2006. 7. 21. 선고 2004가합76058 판결; 서울고등법원 2006. 12. 26. 선고 2006나24157 판결; 서울고등법원 2008. 11. 19. 선고 2008나35779 판결.
95) 서울중앙지방법원 2022. 1. 14. 선고 2021가합512773 판결; 서울남부지방법원 2022. 5. 13. 선고 2021나59869 판결 등 참고.
96) 저작권법 일부개정법률안(대안), 의안번호 18606, 2016. 2. 29. 제안, 2쪽.

및 성격 앞에 두는 경우 영리성·비영리성을 우선적으로 고려하거나 이에 한정하여 판단할 우려가 있어 영리성이 있더라도 공정이용에 해당될 수 있는 행위를 사장시키는 부정적인 효과를 야기하는 것을 방지하기 위한 취지에서 저작권법 개정이 이루어졌으나 실무에서 여전히 상업성·영리성 여부는 중요하게 고려되며,[98] 게다가 이미 삭제된 '보도·비평·교육·연구' 목적과 영리성 판단을 연결시키기도 한다.[99]

그렇다면 차용작품이 갤러리에서의 전시를 통해 판매되어 수익이 발생하는 경우나 미술관에서 전시되는 경우처럼 원저작물을 이용함에 있어 일부 영리적인 목적이 개입되어 있다고 하더라도 비영리적인 목적이 함께 인정되는 경우에는 어떠한가?

이용의 목적 및 성격 요소의 판단 시 '상업적 목적'의 범위에 대해서도 아직까지 명백한 판단 기준이 없다.

모델이 자신이 찍힌 사진을 인스타그램과 구인 사이트에 올려 문제가 된 사안에서 하급심 법원은 피고가 사진 게시에 따른 직접적인 대가로 이익을 취한 것은 아니므로 저작권자인 원고의 이익을 해쳤다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 피고가 구인 사이트 등에 원고의 저작물인 사진을 게시한 행위로 인하여 그에 대한 원고의 저작권이 침해되었다고 단정하기는 어렵다고 판시한 바 있다.[100] 한편, 변리사인 피고인이 교육 목적을 위하여 자신의 블로그에 지적재산권 보호에 관한 정보를 게시하면서 타인의 사진저작물을 인용한 행위에 대하여 법원은 "영리적인 목적으로 이를 인용한 것이 아니고, 이로 인해 직접적인 수익을 얻는 것도 아닌 점", "정보제공과 교육의 목적으로 글을 게시하는 과정에서 이 사건 사진을 삽입한 것일 뿐 인위적인 수정이나 조작을 가하는 등으로 이 사건 사진이 고유하게 가지고 있는 의미를 변경한 것도 아

97) 박준우, "저작물의 공정이용 판단과 변형적 이용 기준의 역할 - 미국 Wofsy v. De Fontbrune 사건에 나타난 문제점을 중심으로", 『계간저작권』, 제36권 제2호, 한국저작권위원회(2023), 94-95쪽: 이러한 개정에 대하여 새로운 저작물이 전혀 변형적이지 않은 경우에도 저작권법상 '공정이용 예시' 시장에서 판매된다는 이유만으로 공정이용이라고 주장하는 것을 어느 정도 방지하는 효과를 기대할 수 있다는 측면에서 적절한 개정이었다는 견해가 있다.

98) 서울동부지방법원 2019. 4. 30. 선고 2019고정94 판결; 의정부지방법원 고양지원 2021. 2. 4. 선고 2020고정762 판결 등 참고.

99) 서울중앙지방법원 2023. 1. 13. 선고 2020가단5004853 판결.

100) 서울중앙지방법원 2020. 9. 10. 선고 2019나73156 판결.

닌 점" 등을 고려하여 저작권 침해로 처벌할 수 없다고 판시한 바 있지만,[101] 이에 대해서는 영리성 기준을 넓게 본다면 변리사의 블로그 운영으로 인해 그 영업에 도움이 될 수 있다는 점에서 영리성이 인정될 수도 있을 것이다.[102] 이와 비슷한 맥락에서 허락 없이 연극 대본과 시나리오를 이용한 행위가 문제된 사안에서 법원은 비록 피고가 자신이 지도하는 학생들의 연극동아리 공연을 위하여 원저작물을 이용하였기 때문에 교육의 목적을 어느 정도 가지고 있다고 하더라도 원고의 항의에 따라 대중을 상대로 예정된 공연이 취소되기는 하였으나, 예정된 공연에서는 일정한 수준의 입장료를 받을 계획이었던 점 이외에 원저작물의 이용은 피고가 기간제교사로서 교사 경력의 첫 단계를 성공적으로 이끌어가는 데 영향을 미치는 활동인 점을 감안하여 저작물의 공정한 이용에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다.[103] 이처럼 영리성의 범위를 넓게 본다면 차용미술의 판매나 전시를 통해 직접적 수익을 얻는 경우뿐 아니라 아트페어의 기획전시나 비엔날레와 같이 미술계에서 공신력을 인정받는 행사에 참여하여 작가로서의 명성을 얻게 되는 경우 영리성이 인정될 수도 있다.

매체나 기술의 발전으로 인하여 창작, 전시나 판매의 유형이나 형태가 다양해짐에 따라 단일 제작되는 미술 작품 이외에 에디션이 있는 복수로 제작되는 미술 작품(multiples) 역시 시장에서 활발하게 거래되고 있으며, 기존의 갤러리나 미술관에서의 전시뿐 아니라 아트페어[104]와 같은 미술 작품 유통이 주된 목적인 행사 또는 백화점이나 오프라인 쇼핑몰과 같은 상업적 성격이 강한 공간에서의 전시 역시 증가하고 있다. 따라서 차용미술의 창작, 전시 또는 판매와 이미지의 이용허락을 구분하여 전자를 영리적 이용 범위에서 일괄적으

101) 서울중앙지방법원 2016. 8. 11. 선고 2016고정382 판결.

102) 저작권법 제29조 제1항의 영리 목적의 공연 또는 방송과 관련하여 직접적으로 영리를 목적으로 하는 경우는 물론 간접적으로라도 영리 추구와 연결될 수 있는 경우에는 이를 비영리 목적의 방송이라 할 수 없다고 해석한 바 있는 반면(서울고등법원 2002. 10. 15. 선고 2002나986 판결), 저작권법 제30조에서 말하는 영리 목적은 복제물을 타인에게 판매하거나 타인으로부터 복제의뢰를 받아 유상으로 복제를 대행하는 등 복제행위를 통하여 직접 이득을 취하는 경우와 같이 직접적인 영리 목적을 의미하는 것이고 저작물의 구입 비용 절감이라는 간접적인 영리 목적까지 포함되는 것은 아니라고 해석한 바 있다(대법원 2020. 7. 29. 선고 2017도1430 판결).

103) 서울중앙지방법원 2018. 5. 4. 선고 2017나76939 판결.

104) 문화체육관광부, 『2022 미술시장조사(2021년 기준)』(2023) 결과에 따르면 2020년 대비 아트페어는 30개가 증가한 65개로 조사되었고 이 중에서 작가 참가 아트페어 역시 41개로 전체의 63.1%를 차지한다.

로 배제하는 것은 적절하지 않으며, 제작 방식, 전시 형태, 작가나 작품에 대한 홍보 정도 등이 개별적으로 고려되어야 할 것이다.

또한 이용의 목적이 상업적·영리적이더라도 그러한 사정만으로 반드시 공정이용에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다. 대부분의 차용미술은 전시와 판매를 통한 소장을 목적으로 창작되는 것이 일반적이기 때문에 원저작물의 2차적 저작물로 인정되는 이상의 상당한 변형성이 인정됨에도 불구하고 미술 시장에서의 판매를 근거로 영리성이 인정된다는 이유만으로 공정이용을 부정하면 차용미술과 관련한 공정이용 법리 자체가 형해화될 가능성이 있다.[105] 따라서 수익의 발생이 있다고 보아 영리성이 인정되더라도 차용미술이 원저작물과 상이한 표현형식 및 목적을 가지고 있는지 여부를 고려하여 해당 차용행위의 공정이용 여부를 최종적으로 검토해야 할 것이다. 마찬가지로 원저작물을 비상업적·비영리적 목적으로 차용한 경우라도 반드시 공정이용에 해당하는 것은 아니다. 하급심 법원 역시 지방선거의 시장 후보자의 SNS 팀장인 피고인이 타인의 사진저작물을 허락을 받지 않고 다른 시장 후보자를 비방하는 게시글에 이용한 행위에 대하여 법원은 "저작물 이용 경위와 목적, 이용 방법 등에 비추어 위 법조 소정의 저작물의 공정한 이용에 해당한다고 보기 어렵고, 피고인이 이 사건 저작물을 상업적 목적에 이용한 것이 아니라고 하여도 마찬가지이다"라고 판시한 바 있다.[106] 따라서 저작물 이용이 상업적·영리적인지 여부는 공정이용의 판단에 있어서 결정적인 요소가 될 수는 없으며, 변형성과 함께 고려되어야 한다.

(4) 저작물의 이용의 목적 및 성격 판단 시 이용자의 의도 고려 여부

스터트번트는 자신의 차용 작업에 대하여 "사고를 유발하기 위하여 복제를 한다"고 밝힌 바 있는데,[107] 이러한 작가의 의도가 저작물의 목적 및 성격,

105) 박경신, 앞의 논문(주 2), 173쪽; 이와 비슷하게 상당수의 변형적 작품은 상업적 목적을 가지고 있으며, 제1요소를 판단할 때 '상업성'에 큰 비중을 두면 결국 공정이용 규정이 사문화될 것이라는 견해가 있다. 박준우, 앞의 논문(주 100), 94쪽.

106) 의정부지방법원 2015. 6. 25. 선고 2015고정646 판결.

107) Michele Chan, Sturtevant: On Repetition and Différence, Sotheby's, 2019. 3. 22., 〈https://www.sothebys.com/en/articles/sturtevant-on-repetition-and-difference〉, (2023. 11. 8. 검색).

특히 변형성 여부를 판단하는 데 고려되어야 할까?

Blanch 판결의 항소심 법원은 원저작물을 차용한 제프리 쿤스(Jeffrey Koons)가 진술한 차용 의도에 주목하였는데, 쿤스는 "감상자가 해당 물체, 제품, 이미지에 관한 자신의 개인적인 경험을 생각하고 이러한 것들이 우리의 삶에 어떻게 영향을 미치는지에 대하여 새로운 관점을 갖기를" 원한다고 주장하였다.[108] 이러한 쿤스의 주장에 대하여 법원은 원저작자는 자신의 사진을 통하여 에로티시즘(eroticism)과 섹슈얼리티(sexuality)를 전하고자 하였다면, 쿤스는 "매스미디어의 사회적·미학적 결과에 대한 자신의 논평을 위한 이야깃거리"로 원저작물을 사용하였다는 이유로 변형성을 인정하였다.[109]

그러나 차용미술 작품의 실질적 의미를 판단하기 위하여 작가의 의도를 고려하는 경우 증거력과 관련하여 상당한 문제를 야기할 수 있는데, 가령 워홀과 같이 작가가 작고하거나 더 이상 대면이 불가능한 작가의 정확한 차용 의도를 파악하기란 어렵다.[110] 게다가 작가가 차용에 있어서 특정 예술적 의도를 가지고 있지 않았다고 진술하거나,[111] 자신의 예술적 의도를 적절하게 표현하지 못하거나, 유리한 소송 결과를 이끌어 내기 위하여 전략적으로 사후 의도를 만들어 낼 수도 있다.

이러한 문제점들을 감안할 때 법원이 변형성 여부를 판단함에 있어 고려해 볼 수 있는 다른 대안은 실질적 유사성을 판단 시 적용되는 통상적 관찰자 또는 "합리적 관찰자(reasonable observer)" 기준이다.[112] *Cariou* 판결의 항소심 법원은 차용미술의 변형성 판단 기준을 "합리적 관찰자(reasonable observer)"로 상정하였으나[113] 이러한 관찰자가 누구인지에 대하여는 명확히 제시하지 않았다. 따라서 유명 작가는 무명작가나 신진 작가에 비하여 자신의 잠재 고객층에게 영향을 미칠 수 있는 가능성이 크다고 할 수 있으며 결과적으로 유명 작가의 저작물 이용 행위는 합리적 관찰자에게 변형적 이용으

108) Blanch v. Koons, 467 F.3d 244, 252 (2d Cir. 2006).
109) *Id.*, at 253.
110) W. K. Wimsatt & M. C. Beardsley, The Intentional Fallacy, 54 Sewanee Rev. 468, 486-487 (1946).
111) Harold Rosenberg, The Art World: De-Aestheticization, University of Chicago Press (1983), pp. 28-38.
112) *Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp.*, 274 F.2d 487, 489 (2d Cir. 1960).
113) 714 F.3d 694, 707 (2d Cir. 2013).

로 인식될 가능성이 클 수 있다.[114] 이러한 이유로 인하여 유명한 소송 당사자가 공정이용 사건에서 승소하는 경향이 있다는 비판이 제기되며,[115] *Cariou* 판결이 대표적이다.[116] 여기에서 항소심 법원은 차용미술의 시장 "공략층"이 원저작물과 동일해야 한다는 전제하에 원저작물과 이를 차용한 작품은 전혀 다른 소장자들을 대상으로 한다는 점을 강조하면서, 이러한 판단을 함에 있어서 리처드 프린스(Richard Prince)의 차용작품들의 전시회가 개최된 갤러리의 오프닝에 "부유하고 유명한 수많은 이들이 참석"하였다는 점과 차용작품들이 천만 달러 이상의 수익을 기록한 반면, 원저작자인 패트릭 카리우(Patrick Cariou)가 적극적으로 자신의 작품을 광고하지 않았고 겨우 8천 달러 이상의 로열티를 받았을 뿐이라는 점이 반영되었다.[117] 그러나 프린스와 카리우 모두 뉴욕시의 갤러리 소유자들과 작품 판매에 관하여 논의 중이었다는 점을 고려할 때 법원의 공정이용의 판단에 영향을 미친 것은 프린스의 명성, 고가로 판매되는 프린스 작품의 가격, 가고시안(Gagosian) 갤러리가 보유한 부유층 연락처 목록이었다는 점은 부인할 수 없다.[118]

이러한 측면에서 대상판결의 다수의견이 잡지사가 원저작물과 〈오렌지 프린스〉의 차이를 인지한 상태에서 〈오렌지 프린스〉를 잡지 표지로 사용하였기에 〈오렌지 프린스〉가 원저작물을 대체하지 않는다고 해석한 반대의견에 동의하지 않으면서 "잡지 편집자 기준(magazine editor test)"을 적용하지 않은 것은 타당하다고 본다. 이용의 목적과 성격 요소에서 잡지사 편집자와 같은 구매자나 전시 작품을 선정하는 미술관 큐레이터가 원저작물 대신에 이를 사용한 새로운 저작물에 미적 측면에서 매력을 느꼈는지 여부나 구매자나 큐레이터가 새로운 저작물이 전달하는 메시지를 선호하였는지 여부를 중요하게 고려하는 경우, 모든 새로운 저작물이 허용될 수 있으며, 작가의 화풍이 보다

114) Andrew Gilden & Timothy Denny Greene, Fair Use for the Rich and Fabulous, 80 U. CHI. L. REV. ONLINE (2013) 88, 100.
115) Matthew Sag, Predicting Fair Use, 73 Ohio St L. J. 47, 78 (2011).
116) Andrew Gilden & Timothy Denny Greene, 앞의 논문, 101쪽; 이에 대한 자세한 논의는 박경신, 앞의 논문(주 2), 73-74쪽.
117) 714 F.3d 694, 709 (2d Cir. 2013).
118) Andrew Gilden & Timothy Denny Greene, 앞의 논문, 99쪽. *Cariou* 판결에 대한 자세한 검토는 박경신, "차용미술과 저작권의 충돌의 해결방안에 관한 재고", 『정보법학』, 제18권 제2호, 한국정보법학회(2014), 65-74쪽 참고.

특징적이고 유명할수록 타인의 저작물을 이용할 수 있는 권리가 광범위하게 부여되는 결과를 야기하기 때문이다.

그러나 이용의 목적 및 성격과 관련하여 변형성의 판단을 위해 누구의 관점을 기준으로 해야 하는지 여부, 특히 목적의 변형 여부의 판단에 있어서 원저작물을 차용한 작가가 실제 의도한 목적이 기준이 되어야 하는지 아니면 합리적 관찰자가 인식할 수 있는 목적이 기준이 되어야 하는지에 대한 명확한 기준이 정립된 것은 아니다. 가령, 스터트번트의 〈Warhol Flowers〉의 경우 앞서 검토한 작가의 차용 의도가 중요하게 고려된다면 변형성이 인정될 가능성이 크지만, 합리적 관찰자나 판사가 개별적인 붓놀림이나 구도, 형태와 같은 객관적 형식적 요소들을 중요하게 고려한다면 워홀의 〈Flowers〉의 2차적저작물로만 인식될 가능성이 크다.

따라서 변형성의 판단에 있어서 작가의 주관적 의도 및 합리적 관찰자나 판사의 개인적 취향과 전문성에 따라 비일관된 기준이 적용되는 문제를 야기하지 않도록 변형성 판단 관점 및 절차에 대한 기준 마련이 필요하다.[119]

Ⅳ. 결론

차용미술의 미술사적 의의나 미술 시장에서의 상업적 성공에도 불구하고 차용은 저작권법의 측면에서 저작재산권, 특히 복제권과 2차적저작물작성권 침해에 해당할 가능성이 크다. 다만 저작재산권 침해에 해당하더라도 공정이용에 해당할 수 있는데 차용미술에 있어서 공정이용 조항의 적용과 관련해서는 우리 법원이 구체적으로 검토한 판결례가 부족한 상황이다.

이러한 상황에서 대상판결은 원저작물과 이를 차용한 작품 사이에 표현상 차이가 존재하지만 동일한 목적으로 사용됐으므로 두 작품 간의 차이는 공정이용을 인정하는 데 충분하지 않다는 결론을 내렸다. 이러한 해석에 따르면 향후 차용미술의 공정이용 판단 시 비교 대상 저작물 간에 예술적 차이가 인정되더라도 이용 목적에 의하여 변형성의 정도가 결정되며 상업성이 함께 고

119) 이에 대한 자세한 논의는 박경신, 앞의 논문(주 57), 143-150쪽 참고.

려되어야 한다. 이는 주관적일 수 있는 작품의 예술적 변형성 판단을 자제하고 작품의 이용 목적을 통해 변형성의 정도를 객관화하고자 한 것으로 최근 미국의 판결들에서 미국 저작권법상 공정이용의 첫 번째 고려 요소와 관련하여 변형적 이용이라는 개념이 지배적인 역할을 하고 있는 추세에 제동이 걸린 것으로 볼 수 있다. 아울러 대상판결은 워홀의 명성과 현대 예술에 기여한 바를 부정할 수 없지만, 그에 비해 덜 알려진 골드스미스와 같은 사진작가의 사진저작물은 유명한 예술가로부터 저작권 보호를 받을 권리가 있으며, 여기에는 2차적저작물작성권이 포함됨을 명확히 확인하였다.

그러나 통상 차용미술과 관련된 저작권 침해 분쟁은 타인의 저작물을 차용하는 행위와 이를 통해 만들어진 작품의 저작권 침해 및 공정이용 여부가 쟁점이 된다는 점에서 워홀의 사망 이후 작품 및 관련 저작권을 양수한 AWF가 워홀의 작품을 상업적으로 이용한 것이 문제가 된 대상판결은 사안의 특수성에 따라 그 논의에 한계가 있다.

그러나 이러한 한계에도 불구하고 우리 저작권법 제35조의5는 한·미 FTA의 체결에 따른 이행의 과정에서 신설되어 미국 저작권법 제107조와 유사하다고 할 수 있으며 모방과 재현을 통한 원작의 해체라는 방식으로 새로운 메시지를 전달하고자 하는 차용미술의 본질적 특성을 감안할 때 미국 저작권법상 공정이용 판단을 위한 고려 요소 중 이용의 목적과 성격과 관련한 대상판결의 변형성 및 상업성 여부에 대한 검토는 차용미술과 관련한 저작권법 제35조의5의 해석에 있어서도 중요하다. 특히 대상판결이 새로운 원저작물에 요소가 추가되었다는 사실만으로 변형성이 인정될 수는 없으며 이용의 목적 및 성격을 판단함에 있어서는 별도의 목적이나 다른 성격이 있는지 여부와 그 정도가 고려되어야 함을 명확히 하였다는 점에서 향후 차용미술과 관련된 우리 저작권법 제35조의5의 해석에 있어서 표현형식의 변형과 목적의 변형을 모두 고려함으로써 공정이용과 2차적저작물작성권과의 상호관계의 규명을 용이하게 하는 방안에 대하여 시사점을 준다. 다만, 미국 저작권법상 공정이용 법리가 우리 저작권법에서 어떻게 수용될 수 있을지에 대한 보다 많은 논의가 필요하다.[120] 나아가 우리 법원은 "저작권자인 피해자의 정당한 이익이 침해될

120) 이와 관련하여 법제 간의 차이에 따른 예측 가능성 확보의 과제, 저작권 보호와의 균형점 설정의 차이 등을 고려하여 미국 저작권법상 공정이용 인정 범위의 확대에 큰 영향을 미친 변형적

수 있는 점"과 상업적·영리적 목적을 중요한 기준으로 적용하거나 출처 명시를 지나치게 강조하기보다는 저작권법 제35조의5의 요소들을 개별적이고 적극적으로 검토함으로써 구체적인 법리를 만들어 갈 필요가 있다. 아울러 공정이용 여부의 판단에 있어서는 개별 요소들에 대한 유기적 고려가 필요하기 때문에, 차용미술의 공정이용 여부의 판단 시 원저작물의 종류, 작품 창작 또는 유통 방식의 변화에 따른 저작권자에게 미치는 경제적 손해 등을 감안하여 최종적인 판단을 할 필요가 있다.

이용 법리의 한계를 적절히 탐색하여 미국 판례상의 기준을 우리 저작권법상 공정이용 규정의 해석에 참고하는 것이 바람직하다는 의견이 있다. 이에 대하서는 류시원, "공정이용 판단의 고려요소로서 '변형적 이용'의 한계 - 미국 연방법원의 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 사건을 중심으로 -", 『계간 저작권』, 제35권 제4호, 한국저작권위원회(2022), 44쪽 참고.

Abstract

A Study on Appropriation Art and Application of Transformativeness under Fair Use Clause of the Korean Copyright Act

- Focusing on the Implication of Andy Warhol Foundation v. Goldsmith

Park, Kyoung-Shin*

Appropriation art borrowing or even directly copying other artists' copyrighted works or other cultural materials is more likely to infringe copyrights under the current copyright system. In this regard, *Andy Warhol Foundation v. Goldsmith,* where the Supreme Court revisit its most salient fair use precedent which introduced the idea of a "transformative use", provides some useful guidance to visual artists to avoid running foul of rights holders– even if it does leave many questions unanswered. The decision is notable for at least two reasons. First, it is the first time the Court has considered whether a visual work qualifies as transformative use. Second, and perhaps more importantly, the decision shifts the focus of the transformative use assessment.

The purpose of the study is to addresses the allowable scope of appropriation art embracing other's copyrighted works under the open-ended fair use clause in the Korean Copyright Act, introduced in 2011 in the course of implementing the Korea-US FTA, focusing on the possibility of application of the standard of a "transformativeness" and the relationship with commerciality of the use of copyrighted works.

* Adjunct Professor, Ewha Womans University, Ph.D. in Law

Keywords

appropriation art, Copyright Act, fair use, commercial use, transformative use

참고문헌

1. 국내문헌

Linda Hutcheon(김상구/윤여복 역), 『패러디이론』, 문예출판사(1995).

계승균, “패러디와 저작권 침해”, 『저작권 문화』, 제314호, 한국저작권위원회(2020).

류시원, “공정이용 판단의 고려요소로서 ‘변형적 이용’의 한계 - 미국 연방법원의 Andy Warhol Foundation v. Goldsmith 사건을 중심으로 -”, 『계간 저작권』 제35권 제4호, 한국저작권위원회(2022).

박경신, “차용미술과 저작권의 충돌의 해결방안에 관한 재고”, 『정보법학』, 제18권 제2호, 한국정보법학회(2014).

_____, “[미국] 법원, 상당한 미적 변형이 없는 경우 공정 이용이 인정될 수 없다”, 『저작권 동향』, 제16호, 한국저작권위원회(2017).

_____, “차용미술의 저작권법상 허용범위의 미적 판단 기준 - 절차적 기준 정립을 중심으로 -”, 『계간 저작권』, 제33권 제1호, 한국저작권위원회(2022).

박일호, “미술작품의 표절에 관한 미학적 접근”, 『현대미술학회 논문집』, 제8호, 현대미술학회(2004).

박준우, “2차적 저작물로의 변형과 공정이용인 변형의 차이 - 표현형식의 변형과 이용목적의 변형 -”, 『상사판례연구』, 제22권 제4호, 한국상사판례학회(2009).

_____, “저작물의 공정이용 판단과 변형적 이용 기준의 역할 - 미국 Wofsy v. De Fontbrune 사건에 나타난 문제점을 중심으로”, 『계간저작권』, 제36권 제2호, 한국저작권위원회(2023).

이일호, “우리 저작권법상 공정이용의 운영 현황과 과제 - 판례를 중심으로 -”, 『계간 저작권』, 제36권 제1호, 한국저작권위원회(2023).

박경신, “차용미술의 저작권법상 허용범위에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원, 박사학위 논문(2019).

문화체육관광부, 『2022 미술시장조사(2021년 기준)』(2023).

대법원 2020. 7. 29. 선고 2017도1430 판결.

서울고등법원 2002. 10. 15. 선고 2002나986 판결.

서울고등법원 2021. 8. 19. 선고 2020나2045644 판결.
서울중앙지방법원 2015. 5. 8. 선고 2015노582 판결.
서울중앙지방법원 2016. 8. 11. 선고 2016고정382 판결.
서울중앙지방법원 2017. 6. 15. 선고 2016가합534984 판결.
서울중앙지방법원 2018. 5. 4. 선고 2017나76939 판결.
서울남부지방법원 2017. 4. 13. 선고 2016노1019 판결.
서울동부지방법원 2019. 4. 30. 선고 2019고정94 판결.
서울중앙지방법원 2019. 8. 14. 선고 2018고정2866 판결.
서울중앙지방법원 2020. 5. 29. 선고 2019노2573 판결.
서울중앙지방법원 2020. 9. 10. 선고 2019나73156 판결.
서울중앙지방법원 2022. 1. 14. 선고 2021가합512773 판결.
서울중앙지방법원 2023. 1. 13. 선고 2020가단5004853 판결.
서울남부지방법원 2016. 6. 3. 선고 2016고정615 판결.
서울남부지방법원 2017. 4. 13. 선고 2016노1019 판결.
의정부지방법원 2015. 6. 25. 선고 2015고정646 판결.
의정부지방법원 고양지원 2021. 2. 4. 선고 2020고정762 판결.
수원지방법원 2020. 11. 13. 선고 2018노5567 판결.
수원지방법원 2021. 6. 17. 선고 2019나2718 판결 .
대구지방법원 2016. 2. 26. 선고 2015고단6154 판결.
청주지방법원 2015. 8. 28. 선고 2015노288 판결.

2. 국외문헌

Harold Rosenberg, The Art World: De-Aestheticization, University of Chicago Press (1983).

Andrew Gilden & Timothy Denny Greene, Fair Use for the Rich and Fabulous, 80 U. CHI. L. REV. ONLINE 88 (2013).

Brian L. Frye, *After Andy Warhol?*, 63 IDEA 280 (2023).

Clark D. Asay et al., Is Transformative Use Eating the World?, 61 B.C.L. REV. 905 (2020).

Liz Brown, Remixing Transformative Use: A Three-Part Proposal for Reform, 4 N.Y.U. J. INTELL. PROP. & ENT. L. 139 (2014).

Matthew Sag, Predicting Fair Use, 73 Ohio St L. J. 47 (2011).

Pierre Leval, Toward a Fair Use Standard, 103 HARV. L. REV. 1105 (1990).

Rebecca Tushnet, Content, Purpose, or Both?, 90 WASH. L. REv. 869 (2015).

Shyamkrishna Balganesh & Peter S. Menell, Misreading Campbell: Lessons from Warhol, 72 Duke Law Journal Online 113, 141 (2023).

William M. Landes, Copyright, Borrowed Images and Appropriation Art: An Economic Approach, 9 GEO. MASON L. REV. 1 (2000).

W. K. Wimsatt & M. C. Beardsley, The Intentional Fallacy, 54 Sewanee Rev. 468 (1946).

Jonathon Keats, Why Is This Warhol Hanging At MoMA? Because Elaine Sturtevant Painted It (And Quite A Few Lichtensteins Too), Forbes, November 25, 2014, 〈https://www.forbes.com/sites/jonathonkeats/2014/11/25/why-is-this-warhol-hanging-at-moma-because-elaine-sturtevant-painted-it-and-quite-a-few-lichtensteins-too/?sh=796fcb381a20〉, (2023. 11. 7. 검색).

Margalit Fox, Elaine Sturtevant, Who Borrowed Others' Work Artfully, Is Dead at 89, The New York Times, May 16, 2014, 〈https://www.nytimes.com/2014/05/17/arts/design/elaine-sturtevant-appropriation-artist-is-dead-at-89.html〉, (2023. 11. 8. 검색).

CastYourArt, "ELAINE STURTEVANT - THE ART OF APPROPRIATING ART", 2015. 3. 11., 〈https://www.castyourart.com/elaine-sturtevant-the-art-of-appropriating-art.html?lang=en〉, (2023. 11. 7. 검색).

Corrina Peipon, Take It Or Leave It: Institution, Image, Ideology, Hammer Museum, 2014, 〈https://hammer.ucla.edu/take-it-or-leave-it/artists/sherrie-levine〉, (2023. 10. 8. 검색).

Famous Photographers, Walker Evans, 〈https://www.famousphotographers.net/walker-evans〉, (2023. 10. 8. 검색).

Tate, APPROPRIATION in Glossary of Art Terms, 〈https://bit.ly/2Qx6AkH〉, (2023. 11. 30. 검색).

Walker Evans, Summary of Walker Evans, The Art Story, 〈https://www.theartstory.org/artist/evans-walker/〉, (2023. 10. 8. 검색).

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 382 F.Supp.3d (S.D.N.Y. 2019).

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 992 F.3d 99 (2d Cir. 2021).

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U. S. ____ (2023).

Blanch v. Koons, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).

Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir, 2013).

Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994).

Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487, 489 (2d Cir. 1960).

TCA Television Corp. v. McCollum, 839 F.3d 168 (2d Cir. 2016).